VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de ação anulatória por meio da qual aproximadamente três centenas de proprietários de terras buscam "*anular a Portaria n. 1.128 de 13 de agosto de 2003, publicada no DOU de 14/08/2003, exarada pelo Sr. Ministro da Justiça, bem como todos os demais atos administrativos anteriores tendentes a modificar, ampliar ou de qualquer forma alterar a área e os limites da Reserva Indígena de Ibirama-La Klânõ, permanecendo o estabelecido no Decreto Presidencial de 15/02/1996, onde a área foi definida em 14.084,8860 hectares*".

Sustentam, para tanto, vícios procedimentais no processo demarcatório, e questionam a tradicionalidade indígena da área, alegando o descumprimento do contido no artigo 231 da Constituição da República.

O caso que ora se apresenta a julgamento, a despeito de referir-se a uma única Terra Indígena, a Ibirama – Laklaño, revela-se de importância ímpar no que concerne aos feitos referentes às demarcações indígenas, por espelhar o modo de ocupação das terras, ao longo do período imperial e republicano pré-Constituição da República, no Sul do País, com as tentativas de pacificação e atração dos povos indígenas para localidades exíguas em dimensão, a fim de possibilitar a concessão dessas áreas para povoamento, a fim de promover a expansão do território ocupado à Oeste, além de liberar terras para a infraestrutura necessária ao alegado desenvolvimento nacional.

O Relatório da Comissão Nacional da Verdade dedicou um Anexo inteiro a problematizar a questão indígena, tratada pelos diversos Governos até 1988 como um entrave às políticas desenvolvimentistas, um problema a ser solucionado, ainda que à base da desagregação, da desterritorialização e do assassinato dessa população:

> "São os planos governamentais que sistematicamente desencadeiam esbulho das terras indígenas.

Cópia

Na década de 1940, Getúlio Vargas inicia uma política federal de exploração e ocupação do Centro-Oeste por colonos – a chamada "Marcha para o Oeste" – contatando populações indígenas isoladas e favorecendo a invasão e titulação de terras indígenas a terceiros. Essa política de "colonização dirigida" já vinha sendo adotada por vários governos estaduais e se encontra desse modo reforçada.

Entre 1930 e 1960, o governo do estado do Paraná titula terras indígenas para empresas de colonização e particulares no oeste do estado. O governo de Moysés Lupion, em particular, notabiliza-se por práticas de espoliação de terras indígenas. Os interesses econômicos de proprietários se faziam representar nas instâncias de poder local para pressionar o avanço da fronteira agrícola sobre áreas indígenas. Em 1958, deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovaram o Projeto de Lei n° 1.077, que tornava devolutas as terras dos índios Kadiweu. Em 1961, o Supremo Tribunal Federal decide pela inconstitucionalidade da lei, mas, a essa altura, estava estabelecida a invasão, uma vez que as terras já tinham sido loteadas (Ribeiro, 1962, pp. 108-112). Além das invasões propriamente ditas, eram comuns arrendamentos de terras que não obedeciam às condições do contrato – quando este havia – ocupando enormes extensões de terras indígenas; constituindo, em alguns casos, situação de acomodação das irregularidades (invasões praticadas e posteriormente legalizadas pelo SPI por meio de contratos de arrendamento).

O relatório da Comissão de Investigação do Ministério do Interior de 1967, presidida pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, constata a existência de problemas desse tipo em quase todo o território nacional e, no caso do esbulho ocorrido no sul do antigo estado do Mato Grosso, traz anexa lista de nomes de beneficiados com terras indígenas e suas vinculações com políticos, juízes, militares e funcionários públicos.

A articulação dessas políticas regionais com um projeto nacional é explicitada, por exemplo, nas resoluções e recomendações aprovadas pela I Conferência Brasileira de

Cópia

Imigração e Colonização, realizada entre abril e maio de 1949, em Goiânia, pelo Conselho de Imigração e Colonização (CIC).

Segundo elas (BRASIL, 1949a, p:4), **a "delimitação das terras habitadas pelos índios" deveria ser acompanhada pelo estabelecimento de colonizações em moldes técnicos nas proximidades: "Facilitar-se-ia, assim, não só a penetração e o desbravamento do *hinterland* brasileiro, como também a assimilação desses nossos patrícios por um processo de aculturação"** (*Idem*). Imediatamente após a Conferência de Goiânia, em maio do mesmo ano, o estado do Paraná e o Ministério da Agricultura firmam um acordo (BRASIL, 1949b) para a "reestruturação" das terras dos povos Guarani e Kaingang, convertendo terras indígenas ocupadas e tituladas no estado em terras devolutas.

Essas violações dos direitos territoriais indígenas que, note-se, estavam garantidos aos índios na Constituição de 1934 (art. 129) e em todas as Constituições subsequentes, estão na origem das graves violações de direitos humanos – como a tentativa de extinção dos Xetá no Paraná, o genocídio dos Avá-Canoeiro no Araguaia e os sucessivos massacres dos Cinta Larga no Mato Grosso, relatados neste texto.

Foram emitidas amiúde declarações oficiais fraudulentas que atestavam a inexistência de índios nas áreas cobiçadas por particulares. Para tomar posse dessas áreas e tornar real essa extinção de índios no papel, empresas e particulares moveram tentativas de extinção física de povos indígenas inteiros – o que configura um genocídio terceirizado – que chegaram a se valer de oferta de alimentos envenenados, contágios propositais, sequestros de crianças, assim como de massacres com armas de fogo. Em 1967, o Relatório Figueiredo, encomendado pelo Ministério do Interior, de mais de 7.000 páginas e 30 volumes, redescoberto em novembro de 2012, denuncia a introdução deliberada de varíola, gripe, tuberculose e sarampo entre os índios."

(http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%20-%20Texto%205.pdf)

Cópia

O que se analisa na presente lide é, precisamente, a consequência trágica dessa política indigenista vigente até a ordenamento constitucional vigente, a confinar os indígenas em pequenas porções de território, insuficientes para a manutenção de seu modo de vida, e abrir as terras à concessão a particulares que, muitas vezes de boa-fé, ocupam essas áreas, e adquirem títulos de domínio, incentivados pelos governos estaduais e federal.

Essa é a configuração da presente demanda, e que certamente repete-se em diversos outros feitos, sendo necessário que esta Corte estabeleça um parâmetro de resolução de tão grave controvérsia, a influenciar a sobrevivência de um grupo indígena e as condições de obtenção de renda por parte dos agricultores que hoje estão estabelecidos na região da demarcação.

Por essa razão, convoquei, em 19.04.2019, audiência de conciliação e diálogo, convidando todos os envolvidos e os *amici curiae* a apresentar propostas para eventual conformação de direitos disponíveis em debate na lide, além de esclarecer a este Julgador pontos sensíveis em discussão no feito, a trazer uma compreensão mais precisa sobre a situação atual das terras em litígio.

Uma vez mais, agradeço a disponibilidade e o espírito de colaboração dos partícipes do ato, que com respeito e tolerância debateram temáticas relativas à tradicionalidade da terra, participação na definição de políticas ambientais para a região, possibilidades para composição das questões patrimoniais e indenizatórias, em relação às quais, se não se encontrou um consenso definitivo entre as partes, prestaram-se a esclarecer o Juízo e a colaborar com a produção da decisão que ora se coloca a julgamento.

Dentro de uma concepção participativa de democracia e justiça, quando o Poder Judiciário é chamado a compor um conflito de magnitude constitucional, haurindo as complexidades e desafios inerentes à questão indígena no Brasil, mostra-se essencial a exposição dos dissensos e a busca por uma resolução pacificadora e concretizadora dos direitos fundamentais esculpidos pela Carta Republicana de 1988.

Cópia

As reflexões levadas a cabo na audiência, bem como as diversas manifestações posteriores acerca das propostas surgidas no ato, formaram substrato fundamental para a decisão que passo a expor.

Histórico da ocupação e expulsão indígena da área

Ao longo dos cento e vinte volumes que compõem o presente feito, restou demonstrado que a área em litígio foi ocupada, ao menos até o início do século passado, pelos indígenas da etnia *Xokleng*. Reside o ponto controvertido, portanto, em saber se a expulsão dos índios dessas terras de forma forçada permite caracterizar a perda da posse tradicional, ou se a expulsão violenta da comunidade não descaracterizou a ligação anímica entre os indígenas e a terra, a fazer incidir a tutela disposta no artigo 231 da Constituição Federal, *in verbis*:

> "Art. 231. **São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.**
>
> § 1º **São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições**.
>
> § 2º **As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes**.
>
> § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades

Cópia

> afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
>
> § 4º **As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis**.
>
> § 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
>
> § 6º **São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé**.
>
> § 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º."

De fato, ocupam a área demarcada em 1996 como Terra Indígena Duque de Caxias, os povos *Xokleng, Kaingang* e *Guarani,* com predominância populacional do primeiro grupo, que ocupava a área de modo tradicional, e que buscaram junto à FUNAI o reconhecimento de seus direitos constitucionais à posse tradicional da área de 37.108 hectares, denominada pela Portaria nº 1.128/2033-MJ, em atendimento à vontade da comunidade, como Terra Indígena Ibirama-Laklaño.

A perseguição aos índios *Xokleng*, denominados botocudos pelos brancos, efetivou-se de modo bastante violento no período imperial, vindo a converter-se em tentativas de "pacificação" - não menos agressivas e mortais – já sob a tutela do Serviço de Proteção ao Índio – SPI.

A perícia judicial antropológica (Pet 75282/2010, autos 08/19) bem

evidencia esse transcurso histórico dramático ao povo *Xokleng* do Alto Vale do Itajaí, desde as primeiras tentativas de aldeamento até a finalização do Acordo efetivado entre o Estado de Santa Catarina e o SPI, que reduziu as terras para a habitação dos índios, possibilitando a concessão das áreas mais férteis à colonização dos europeus e seus descendentes:

> "Em 1914 ocorre o dito processo de "Pacificação" dos Xokleng na área da Foz do Rio Platê (interior da atual TI). Utilizo as expressões aldeamento, contato e sedentarização em detrimento de pacificação, uma vez que esta acarreta uma conotação negativa de submissão para os indígenas, não fazendo jus aos acontecimentos.
>
> A pesquisa documental levada a cabo por Santos (1987:28-39) demonstra que o território Xokleng, à época da chegada dos europeus, se estendia de Curitiba a Porto Alegre, desde o litoral até o planalto. Território este que já vinha sendo ocupado desde pelo menos cinco mil anos antes do presente. Este território foi sendo reduzido pela pressão colonizadora vinda do planalto, por um lado, e dos vales litorâneos, por outro, deixando-os restritos às áreas de maior declividade. Trinta anos antes da sua atração e aldeamento no Vale do Rio Platê, um dos três grupos Xokleng identificados em Santa Catarina ocupava um território que compreendia o médio e o alto Vale do ltajaí. Sílvio Coelho dos Santos identificou em correspondência do ano de 1878 entre a Direção da Colônia Blumenau e a Cia. De Pedestres-encarregada de realizar *"expedições em perseguição aos bugres"*- a constatação de que havia um *"acampamento principal localizado entre as bacias do* Benedito, Rio Preto e Itajahy do Norte, pois picadas daqui, como as da região serrana (…) *têm todas a direção para a dita região"* (1987:72-76). A localidade do referido acampamento deveria distar aproximadamente dez quilômetros, em linha reta, do limite norte da atual TI.
>
> Os indígenas encontravam-se premidos por dificuldades de sobrevivência, pela situação de elevado número de crianças órfãs decorrentes dos conflitos com os colonos (utilizo as

Cópia

denominações colonos ou agricultores familiares, preferida por eles atualmente, conforme o contexto da narrativa) e, principalmente, pela ação de grupos bugreiros que, desde 1874 adentravam as matas para "caçar os índios", afugentá-los para longe dos lugares que estavam sendo ocupados pelos colonizadores. Aqueles bugreiros partiam das colônias de Joinville, Blumenau, Florianópolis, Lages, frequentemente acompanhando os serviços dos agrimensores de terras (Santos, 1997 :27).

À medida que as famílias avançam nas frentes de colonização, os confrontos com os indígenas se sucediam. Com os seus territórios de caça sendo suprimidos os Xokleng passaram a enfrentar fome e, consequentemente, a assaltar as lavouras, ferramentas e os animais de criação dos agricultores.

A violência e crueldade desse confronto foram relatadas em periódicos da época e, naturalmente, pelos próprios indígenas. A tentativa de extermínio dos grupos indígenas para atender o interesse do Governo de Santa Catarina e de companhias colonizadoras (negociadoras de terras com imigrantes europeus) de pôr fim aos ataques e confrontos entre colonos e índios, se estendeu desde 1874 até um pouco depois de 1910, quando foi criado pelo governo federal o SPI (Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais). Como resultado de amplo debate nacional e internacional movido por intelectuais e políticos humanistas e republicanos que denunciavam o genocídio, concedendo aos indígenas o *status* de seres humanos, se impôs o fim da perspectiva de eliminação e a sua substituição pela perspectiva de integração do indígena à civilização.

O efetivo contato provocou, então, a segunda forma de extermínio, normalmente, porém não sempre, ocorrido supostamente de forma não intencional, provocado por vírus e bactérias comuns para os europeus, porém fatais aos povos americanos (gripe, sarampo e varíola foram as mais comuns). Dos 400 indivíduos atraídos em 1914, restavam apenas 106 em 1932. Foram 294 mortes em 18 anos. Sobre as consequências

Cópia

desta depopulação, afirma Santos (1987:181):

A morte de tão elevado número de pessoa, no curto espaço de 18 anos, naturalmente marcou definitivamente o comportamento indígena perante os brancos. Segundo Ribeiro (1970:313) os mais importantes cerimoniais do grupo, a furação dos lábios dos meninos e a cremação dos mortos, foram abolidos logo após a primeira epidemia de gripe. Isto, por dois motivos: primeiro devido ao abatimento em que todos caíram ficando sem ânimo para festanças; segundo, porque eram tantos os mortos que se tornara impossível fazer grandes piras fúnebres. E por parte do pacificador, preocupado com a propagação das doenças, tratou logo de desestimular ajuntamentos.

Esta situação levou o responsável pela atração em 1914 e então Chefe do Posto Indígena, Eduardo de Lima e Silva Hoerhan a dizer, em entrevista ao antropólogo Darcy Ribeiro na década de 1960, que "se pudesse prever que iria vê-los morrer tão miseravelmente, os teria deixado na mata, onde ao menos morreriam mais felizes e defendendo-se de armas na mão contra os bugreiros" (Ribeiro, 1970:316).

A tática do contato foi oferecer-lhes como presentes alimentos, principalmente na forma de carne de gado, milho e cana de açúcar, produzidos inicialmente pelo trabalho dos funcionários do posto indígena, bem como medicamentos para as epidemias que enfrentavam. Hoerhan procurou logo envolver os indígenas na produção dos alimentos, no que teve muita resistência por parte dos mesmos. Este aspecto é explorado pela historiadora Luisa Wittmann (2010) a partir dos relatórios redigidos pelo próprio Hoerhan na década de 1920.

Este respeito afirma Clédes Markus,

Após os contatos realizados com os indígenas, começou toda uma empreitada para integrá-los à sociedade envolvente e transformá-los em agricultores. Este intento aconteceu com muito sofrimento para

Cópia

os Xokleng, que se viram frente a trabalhos forçados e submetidos a castigos quando não faziam o que lhes era ordenado. Com razão, muitas vezes se refugiavam nas matas, mas eram trazidos de volta pelos caçadores e penalidades maiores lhes eram impostas.

Desta forma, se viram obrigados a uma adaptação que hoje os Xokleng consideram uma grande traição dos não-indígenas (2006: 38).

Os escassos recursos financeiros recebidos pelo Posto Indígena para manter um suprimento abundante de alimentos, aliado à persistência indígena em manter seu modo de vida nômade com incursões de caça e coleta de pinhões *(Araucaria angustifolia),* gerou dificuldades para mantê-los restritos ao território então reservado. Nos primeiros anos de aldeamento os indígenas tomavam parte nas lides de derrubadas de mata e preparo de roças, alternando-as com suas excursões de caça e coleta. Devido à necessidade de restringir de seu território indígena tradicional de perambulação na busca de caça e coleta, também se fez necessário arrendar terras do Posto Indígena a regionais que pagavam na forma de víveres e dinheiro para o consumo dos indígenas. Estes arrendamentos ocorreram na região de Barra da Prata, Rio Denicke, Rio Bruno e Rio das Frutas a partir da década de 1940.

Enquanto Eduardo de Lima e Silva Hoerhan foi chefe do Posto Indígena, até 1954, tentava proibir a abertura de estradas, a exploração florestal e fazia grande esforço para impedir o convívio dos índios com os brancos para que aqueles não fossem influenciados pelos seus valores culturais nem explorados em sua mão de obra e nos recursos do seu território. Contudo, a exígua verba que historicamente o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) designou às despesas de manutenção do Posto Indígena, somada à necessidade de impor aos indígenas a restrição do acesso ao seu território tradicional por causa da chegada paulatina de ocupantes de origem européia, aliado ao seu estilo autoritário de exercer a chefia, tornavam tarefa quase impossível para Hoerhan evitar que os indígenas passassem a

aceitar as afirmações dos brancos de que seu modo de vida era infinitamente vantajoso à realidade que viviam.

(…)

Por volta de 1912, quando foram iniciadas as tentativas de atração dos Xokleng no Alto Vale do Itajaí, a Sociedade Colonizadora Hanseática pretendeu fazer a doação de três mil hectares de terras para a fixação dos silvícolas na região do Taió, a parte mais longínqua de sua concessão, a noroeste da atual TI (Deeke, apud Santos, 1987:197). No entanto, o contato e o processo de aldeamento deu-se na Foz do Rio Platê, 100 km distante daquele ponto inicialmente previsto. Ali os Xokleng vinham inicialmente buscar alimentos, ocasiões nas quais Eduardo insistia para que permanecessem, porém seguiram ocupando uma área muito mais extensa do que três mil hectares, que continha áreas de perambulação de caça e coleta nas regiões dos pinheirais de Araucária. Os pinheirais mais próximos ficavam a oeste, atual Serra da Abelha, e a norte, atual Bom Sucesso.

O grupo de 400 indígenas atraídos para o PI em 1914 seguiu perambulando à revelia e para a exasperação do chefe do posto, Hoerhan, como se depreende dos relatórios escritos pelo mesmo ao SPI. (Santos, 1987; Hoerhann, 2008[1]) Também se lê nestes relatórios que a área reservada aos indígenas encontrava-se indefinida.

Desde 1914, quando ocorreu a atração, até 1950, a área efetivamente ocupada pelos indígenas se expandia muito além dos 20 mil hectares reservados aos indígenas em 1926, e também além dos 37.108,39 mil hectares da área de redelimitação ora reivindicada. Os indígenas eram informados, embora sem muita precisão, sobre quais deveriam ser os limites para a sua perambulação. A este respeito, declara Veitiá Teié, 88 anos, morador da TI:

Toda a terra, subindo o rio da Prata, cruzando o Rio Jtajaí, vai em direção a Bom Sucesso e vem descendo pro cá, tudo isso aí a gente tá por dentro, quando os índios vieram fora (do

mato) em 1914, isso foi aguado (sic) junto com o primeiro chefe, o Eduardo de Lima e Silva, e quem estava junto que aguou era Otto Lira, ele era chefe da Companhia Hanseática.

Advém daquele período inicial a clareza que os indígenas têm a respeito do direito sobre a área que hoje reivindicam. Argumentam que Eduardo apontava a eles estes limites para que pudessem caçar e ordenava que não saíssem dos mesmos. Qualquer saída estava vinculada a uma autorização expedida por Hoerhan, sob pena de serem punidos fisicamente, o que realmente acontecia, como revelaram depoimentos de índios e regionais colhidos em nossa pesquisa. "Quem sair fora disso não é terra de vocês", teria dito Eduardo Hoerhan, segundo depoimentos de índios idosos.

Em 1926, doze anos após a atração, pressionado pelo então chefe de posto Eduardo de Lima e Silva Hoerhan que enfrentava inúmeros problemas com intrusos da área que então ele apontava como sendo reservada, não oficialmente, aos indígenas - o Governo do Estado de Santa Catarina, por ato do então governador Antônio Vicente Bulcão Vianna, expediu o Decreto 15/1926, que criou a Reserva Indígena Duque de Caixas, com perímetro que confrontava, em sua maior parte, com terras que já haviam sido concedidas a empresas colonizadoras. Ficou ali incluída a região da Barra da Prata, porém ficaram fora da área reservada as áreas mais planas da região, bem como as que continham florestas de araucária.

Hoerhan celebrava, em relatório escrito no ano de 1927, que o Decreto 15/1926 teria reservado aos indígenas uma área de 20 a 30 mil hectares, certamente por desconhecer, na ocasião, que a terra reservada havia sido de **20 mil hectares** (Hoerhann, 2008[2]). Compreende-se, então, porque o território de redelimitação ora reivindicado pela comunidade indígena da TI Ibirama-LaKlãno seja aquele que Hoerhan indicava aos indígenas como sendo os seus limites, tendo percorrido com

Cópia

> eles as divisas, conforme depoimentos de indígenas mais idosos.
>
> (…)
>
> **Uma evidência de que uma área mais ampla do que a decretada em 1926 era utilizada pelos indígenas é a carta escrita em 1940 pelo então deputado de Santa Catarina, Adolpho Konder, ao Marechal Cândido Rondon, após visitar a Reserva Indígena. Nesta carta Konder afirma que a área ocupada pelos índios era de 30 mil hectares** (Anexo 7).
>
> **Em 1952 este mesmo tipo de pressão gerou a desanexação de 6 mil hectares da Terra Indígena - as áreas da Barra da Prata, Rio Bruno e Rio Denecke -, considerando a existência, então, de madeireiros e agricultores "intrusados" naquela região. Isso ocorreu através de acordo firmado entre o governo federal, através da 7a Inspetoria do Serviço de Proteção aos Índios - SPI e o governo estadual de Santa Catarina, através da Diretoria de Terras e Colonização de Santa Catarina - DTC/SC, que alterou os limites descritos no Decreto de 15 de 1926, reduzindo a extensão da Terra Indígena para 14.048,88 hectares (Oficio 141/52 da DTC/Secretaria de Agricultura/Estado de Santa Catarina). Em 1996 a Presidência da República homologou esta situação fundiária da Terra Indígena IbiramaLakLãno**."

Bem exposta, pois, a problemática fundiária existente na região. A política de aldeamento e confinamento indígena, para liberação de terras à colonização, foi prática corrente na região Sul do País, a permitir a ocupação do interior por imigrantes e seus descendentes que chegavam ao Brasil no começo do século. No entanto, no caso *Xokleng*, apesar da violência com que foram reprimidos em seus direitos, eles permaneciam a perambular e desenvolver suas práticas tradicionais, o que levou ao Decreto Estadual nº 15, de 1926, determinando uma reserva de área de 20 mil hectares aos índios e, posteriormente, à edição do Acordo de 1952, por meio do qual Estado de Santa Catarina e SPI reduzem a área para 14 mil hectares, que acabou por ser homologada por Decreto Presidencial de

15.02.1996.

Nesse ínterim, contudo, adiciona-se outro componente a demonstrar a fragilidade da situação fática da Comunidade Indígena na região: a construção da Barragem Norte, incidente nas terras que se reconhecera como "reserva indígena", e que retira aproximadamente 95% das terras férteis disponíveis aos índios, gerando desintegração nas aldeias e consequências que, como se demonstrou na audiência de conciliação e diálogo, perduram até os dias atuais.

Como assevera o laudo judicial:

> "A história de subtração e exploração do território indígena Ibirama-LaKlãno até aqui apresentada - com seus efeitos modificadores sobre o modo de vida tradicional indígena - sempre se processou sob a aquiescência do órgão federal indigenista (SPI) contemplando os interesses de empresários que se beneficiaram com a extração prévia da madeira nativa das áreas a serem colonizadas e do Governo do Estado de Santa Catarina, que vendeu lotes aos agricultores necessitados de terras.
>
> Aquiescência aquela relativa, que podemos atribuir à situação de desamparo administrativo e jurídico a que eram relegados os funcionários locais do SPI, uma vez que os relatórios do então chefe do Posto Indígena, Eduardo Hoerhan, em 1927, descrevem uma constante tensão com regionais que insistiam em invadir e ocupar áreas no interior do território indígena, inclusive aquelas ocupadas com roças indígenas. (Hoerhann, 2008:32).
>
> **Não foi diferente a posição do órgão indigenista, então já Fundação Nacional do Índio- FUNAI, quando em 1975 o Decreto Federal n° 76.392 declarou de utilidade pública parte das terras indígenas Xokleng para a construção da Barragem Norte do Alto Vale do Itajaí.**
>
> **Em 1976 iniciaram as obras sem nenhum cuidado de proteção dos direitos da população indígena. Entre 1978 e 1984 a área indígena sofreu cinco enchentes causadas pelas obras da Barragem Norte. A primeira delas foi especialmente**

Cópia

traumática. Foram pegos de surpresa, pois todos, com exceção dos Guarani, moravam nas várzeas do Rio Itajaí do Norte (Hercílio). Praticamente todas as casas, plantações e pomares foram destruídos. Os novos locais de moradia localizaram-se agora em áreas elevadas, de relevo íngreme e terras pobres. A retomada das roças tornou-se extremamente dificultosa. É possível verificar no mapa de declividades (Anexo 2) o relevo acidentado ao longo da estrada na qual se localizam as aldeias. (Foto 4)

A criação de uma área que seria o lago de represamento eventual da Barragem justificou a radicalização da extração florestal, que continuou a se processar nos mesmos moldes de relações entre índios e não índios descritos acima. A extração florestal, no entanto, não ficou restrita à área de represamento.

No ano de 1980 a comunidade indígena recebeu uma pequena indenização em forma de dinheiro pelas casas de madeira e pomares destruídos pela enchente de 1978. No entanto, não teve qualquer sinalização de outras formas de indenização até o ano de 1981, quando o Convênio 029/81 (Anexo 3) celebrado entre Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS - e Fundação Nacional do Índio - FUNAI previu a remoção de famílias das áreas a serem alagadas, a construção de benfeitorias, de casas, estradas, pontes, eletrificação, canalização de água, indenização pelas roças e pomares, execução de projeto de desenvolvimento agrícola e florestal. Foi então prevista a construção de 63 casas de madeira, das quais apenas 30 foram executadas, e a comunidade recebeu indenizações pela perda das árvores frutíferas.

Note-se que até 1984 não haviam sido feitas obras de construção de casas, pontes, eletrificação, tampouco o projeto de desenvolvimento agrícola e florestal. Naquela data o convênio 029/81 foi re-ratificado e recebeu um segundo aditivo (Anexo 4). O texto menciona que parte da verba prevista para o projeto de desenvolvimento agrícola e florestal já havia sido repassada à FUNAI. Previu-se então, cláusula primeira:

Cópia

d- a indenização, por utilização pelo DNOS, da área de 856, 527 hectares de propriedade da Reserva Indígena Duque de Caxias, de Ibirama, sendo 817,4270 ha. localizados na bacia de acumulação (. ..) e 39, 1 O ha. Localizados acima da cota da citada bacia de acumulação, necessários à construção de estradas de contorno.

e- a indenização dos danos materiais decorrentes do represamento das águas do Rio Hercilio ocorrido em maio/83.

Os valores de repasse à FUNAI, responsável pela execução das obras e indenizações também foram acrescidos. Não obtive a informação precisa quanto à completude dos repasses nem aos motivos pelos quais as verbas não foram aplicadas da forma prevista. O que se percebe no histórico das negociações de indenizações é que o grupo indígena foi acumulando prejuízos em cada uma das enchentes, bem como passou a perceber que deveriam ser indenizados também pela parte do território perdido para a Barragem.

Um novo convênio, sob número 041/98 (Anexo 5) envolvendo a União, Estado de SC e FUNAI previu a construção de estradas de acesso, redes de energia elétrica e edificações, "com vistas a compensar os prejuízos verificados na Reserva Indígena decorrentes da construção da Barragem Norte do Vale do Itajaí/SC." Foram ali novamente elencadas as obras não realizadas desde o Convênio de 1981: a construção de duas pontes pênseis sobre o Rio ltajaí do Norte (Hercílio) interligando aldeias, um campo de futebol, uma igreja com 240 m2, estradas ligando a aldeia Sede à aldeia Bugiu e à aldeia Toldo.

Ademais, previu-se a finalização de 188 casas que haviam ficado inacabadas. Acrescentou-se mais 96 casas, demanda surgida com aumento da população indígena. Atualmente a situação de indenizações continua com pendências que se arrastam há 12 anos. Some-se a isto o fato de que muitas das casas construídas já requerem manutenção, tal como troca de madeiramento do telhado e assoalho. Até a presente data

Cópia

nenhuma ação do Programa Ibirama, projeto de desenvolvimento agrícola e florestal, foi executada pela FUNAI.

(…)

Ressalto que os convênios mencionados acima têm por trás de si inúmeras mobilizações e pressões indígenas para que fossem realizados. Realização de viagens para encontrar autoridades políticas, constante pressão junto aos poderes públicos, apreensão de funcionários da FUNAI, embargo das obras, e, sobretudo, sua forma mais contundente de pressão, os acampamentos em locais estratégicos como forma de chamar a atenção da sociedade abrangente para as suas demandas e dificuldades.

Este período que vai da primeira enchente, em 1978, até por volta de 1995, foi marcado por enormes dificuldades materiais e psicológicas para a população indígena. Com a desestruturação da produção de alimentos, enfrentaram fome nos primeiros anos. Ocorreu uma forçada reconfiguração cultural, social, política e espacial que passou por diversas etapas, culminando na formação atual de sete aldeias. *"Na primeira enchente, tudo o que era dos índios ficou em baixo da água. Houve outros dois outros traçados de estrada mais para baixo. Este é o terceiro traçado. As famílias foram se deslocando gradualmente"*, informou Natalina Vergueiro, índia Xokleng, funcionária da FUNAI.

Outro aspecto traumático para a comunidade foi a da saída de muitas famílias da área indígena indo morar em outras cidades da região, movimento este iniciado após a primeira enchente. O principais destinos destas famílias são Blumenau, Rio do Sul, Indaial, Pomerode, Navegantes e Itajaí no Vale do Itajaí, além de Joinville, Florianópolis, Balneário Camboriú, além de algumas nos Estados de São Paulo e Paraná. Os entrevistados afirmaram que o motivo deste êxodo foi a falta de espaço para estabelecer novas residências e as dificuldades para sobreviver. Também podemos ponderar que diante da instabilidade e da violência decorrentes dos deslocamentos das moradias, das disputas internas que foram aí geradas ou

Cópia

> acirradas ao longo dos 20 anos nos quais a barragem esteve em construção, tratou-se de um movimento de auto-preservação este de indígenas que decidiram se mudar para outros municípios.
>
> (…)
>
> Assim, a amplitude do impacto daquela obra sobre a população indígena é reconhecida por todos os pesquisadores que se debruçaram sobre a Terra Indígena IbiramaLaKlãno. Independente do tema da pesquisa - educação, arquitetura, economia, ciências naturais, etnografias - impõem-se a percepção de que a Barragem provocou alterações profundas no modo de vida, na organização política e sócio espacial, na sua auto-imagem, no processo de revitalização da identidade étnica e no relacionamento com a sociedade branca.
>
> A Constituição 1988 criou a possibilidade de ampliar a sua perspectiva sobre os direitos territoriais e toda a mobilização que já vinha ocorrendo em torno dos direitos por indenizações encampou também a causa da redelimitação da TI."

Cópia

Traçado todo o percurso histórico do povo *Xokleng* em busca dos seus direitos, apesar da condições desfavoráveis a ele imposta pelos governos federal e estadual, sob a tutela dos órgãos indigenistas, que reputei necessário apontar a fim de que o caso tenha a compreensão devida, incumbe analisar as alegações lançadas na exordial, que impugna o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação da Terra Indígena Ibirama-Laklaño, pela Portaria nº 1.128/2003, do Ministro da Justiça.

Principio pelas alegações de vícios procedimentais no processo administrativo demarcatório.

<u>Dos alegados vícios formais do procedimento administrativo demarcatório</u>

Repisando o *caput* do artigo 231 do texto constitucional, "*São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e*

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens".

Portanto, e em se considerando que, nos termos do artigo 20, XI da Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são de domínio da União, trata-se a demarcação de procedimento administrativo da União, a identificar essas terras e demarcá-las no interesse das comunidades indígenas que ocupam de modo tradicional essas áreas.

A demarcação administrativa é prevista pelo Estatuto do Índio, que em seu artigo 19 assim dispõe:

> "Art. 19. **As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo**.
>
> § 1º A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente da República, será registrada em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) e do registro imobiliário da comarca da situação das terras.
>
> § 2º Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a concessão de interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou à demarcatória."

O longo e complexo procedimento para demarcar uma terra indígena é regulamentado, por sua vez, pelo Decreto nº 1.775/1996:

> "Art. 1º **As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 6001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da Constituição, serão administrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio, de acordo com o disposto neste Decreto**.
>
> Art. 2° **A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida,**

Cópia

que elaborará, em prazo fixado na portaria de nomeação baixada pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, estudo antropológico de identificação.

§ 1° **O órgão federal de assistência ao índio designará grupo técnico especializado, composto preferencialmente por servidores do próprio quadro funcional, coordenado por antropólogo, com a finalidade de realizar estudos complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessários à delimitação**.

§ 2º **O levantamento fundiário de que trata o parágrafo anterior, será realizado, quando necessário, conjuntamente com o órgão federal ou estadual específico, cujos técnicos serão designados no prazo de vinte dias contados da data do recebimento da solicitação do órgão federal de assistência ao índio**.

§ 3° **O grupo indígena envolvido, representado segundo suas formas próprias, participará do procedimento em todas as suas fases**.

§ 4° O grupo técnico solicitará, quando for o caso, a colaboração de membros da comunidade científica ou de outros órgãos públicos para embasar os estudos de que trata este artigo.

§ 5º No prazo de trinta dias contados da data da publicação do ato que constituir o grupo técnico, os órgãos públicos devem, no âmbito de suas competências, e às entidades civis é facultado, prestar-lhe informações sobre a área objeto da identificação.

§ 6° Concluídos os trabalhos de identificação e delimitação, o grupo técnico apresentará relatório circunstanciado ao órgão federal de assistência ao índio, caracterizando a terra indígena a ser demarcada.

§ 7° **Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, este fará publicar, no prazo de quinze dias contados da data que o receber, resumo do mesmo no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade**

Cópia

federada onde se localizar a área sob demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, devendo a publicação ser afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel.

§ 8° **Desde o início do procedimento demarcatório até noventa dias após a publicação de que trata o parágrafo anterior, poderão os Estados e municípios em que se localize a área sob demarcação e demais interessados manifestar-se, apresentando ao órgão federal de assistência ao índio razões instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas, para o fim de pleitear indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do relatório de que trata o parágrafo anterior**.

§ 9° Nos sessenta dias subseqüentes ao encerramento do prazo de que trata o parágrafo anterior, o órgão federal de assistência ao índio encaminhará o respectivo procedimento ao Ministro de Estado da Justiça, juntamente com pareceres relativos às razões e provas apresentadas.

§ 10. Em até trinta dias após o recebimento do procedimento, o Ministro de Estado da Justiça decidirá:

I - declarando, mediante portaria, os limites da terra indígena e determinando a sua demarcação;

II - prescrevendo todas as diligências que julgue necessárias, as quais deverão ser cumpridas no prazo de noventa dias;

III - desaprovando a identificação e retornando os autos ao órgão federal de assistência ao índio, mediante decisão fundamentada, circunscrita ao não atendimento do disposto no § 1º do art. 231 da Constituição e demais disposições pertinentes.

Art. 3° Os trabalhos de identificação e delimitação de terras indígenas realizados anteriormente poderão ser considerados pelo órgão federal de assistência ao índio para efeito de demarcação, desde que compatíveis com os princípios

> estabelecidos neste Decreto.
>
> Art. 4° Verificada a presença de ocupantes não índios na área sob demarcação, o órgão fundiário federal dará prioridade ao respectivo reassentamento, segundo o levantamento efetuado pelo grupo técnico, observada a legislação pertinente.
>
> Art. 5° A demarcação das terras indígenas, obedecido o procedimento administrativo deste Decreto, será homologada mediante decreto.
>
> Art. 6° Em até trinta dias após a publicação do decreto de homologação, o órgão federal de assistência ao índio promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda.
>
> Art. 7° O órgão federal de assistência ao índio poderá, no exercício do poder de polícia previsto no inciso VII do art. 1° da Lei n° 5.371, de 5 de dezembro de 1967, disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros em áreas em que se constate a presença de índios isolados, bem como tomar as providências necessárias à proteção aos índios.
>
> Art. 8° O Ministro de Estado da Justiça expedirá as instruções necessárias à execução do disposto neste Decreto."

No entanto, como se depreende do próprio texto constitucional, os direitos territoriais originários dos índios são reconhecidos, portanto, preexistem à promulgação da Constituição.

Logo, e como bem explicita o Estatuto do Índio, em disposição consonante com o texto constitucional, a demarcação não constitui a terra indígena, mas apenas declara que a área é de ocupação pelo modo de viver indígena:

> "Art. 25. **O reconhecimento do direito dos índios e**

> **grupos tribais à posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas**, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República."

Como bem ressalta a doutrina:

> "**O procedimento demarcatório tem natureza meramente declaratória, pois o que se busca com ele é apenas a delimitação da área já pertencente e aos povos indígenas, em razão dos direitos que decorrem da ocupação tradicional**. O reconhecimento da propriedade, em caráter originário, é de viés constitucional, conforme estabelecido no muitas vezes citado art. 231 da Constituição."
>
> (VITORELLI, Edilson. Estatuto do Índio: Lei 6.001/1973. 4.ed. Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 177-178)

Logo, a natureza jurídica do procedimento demarcatório é meramente declaratória, porquanto consiste na exteriorização da propriedade da União, vinculada e afetada à específica função de servir de *habitat* para a etnia que a ocupe tradicionalmente, representando atividade do Poder Executivo, desempenhada por diversos órgãos, conforme o procedimento acima demonstrado, mas que não cria terra indígena, apenas reconhece aquelas que já são, por direito originário, de posse daquela comunidade.

Nesse esteio, a Fundação Nacional do Índio, ao atender reivindicação da Comunidade Indígena *Xokleng*, instaurou pela Portaria 418/PRES/95, para "*Constituir Grupo Técnico com a finalidade de proceder estudos preliminares na área de terras do Decreto nº 015, de 03 de abril de 1926, reservada para usufruto dos indígenas, excluída da demarcação atual da terra indígena IBIRAMA, localizada nos municípios de Ibirama e Itaiópolis, Estado de Santa Catarina*".

O procedimento foi levado a cabo, culminando com a prolação de Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Ibirama-Laklaño, posteriormente aprovado pelo Ministro da Justiça, que demarcou a terra na extensão ali indicada.

Em relação a esse *iter* procedimental, os autores elencam vícios a macular, em seu entendimento, a higidez da demarcação administrativa.

Em primeiro lugar, sustentam que procedimento administrativo deixou de atender o disposto no Decreto nº 1.775/1996 e ao princípio constitucional da ampla defesa, diante da ausência de citação dos atingidos pela demarcação para participar do processo, bem como pela ausência de descrição de todas as propriedades de não-índios quando do levantamento fundiário realizado.

De plano, cumpre apontar que o processo administrativo demarcatório disciplinado pelo Decreto nº 1.775/1996 foi considerado constitucional pelo Plenário desta Corte, conforme acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 24.045:

> "EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA INDEFERIDA. Imprescindibilidade de citação da FUNAI como litisconsorte passiva necessária e ausência de direito líquido e certo, por tratar a questão de matéria fática. Preliminares rejeitadas. **Ao estabelecer um procedimento diferenciado para a contestação de processos demarcatórios que se iniciaram antes de sua vigência, o Decreto 1.775/1996 não fere o direito ao contraditório e à ampla defesa. Proporcionalidade das normas impugnadas.** Precedentes. Segurança indeferida."
>
> (MS 24045, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 28/04/2005, DJ 05-08-2005 PP-00006 EMENT VOL-02199-01 PP-00197 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 145-154)

Nesse sentido, também se pronunciou a Corte no julgamento da Pet nº 3.388:

> "3. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEMARCATÓRIO. **3.1. Processo que observou as regras do Decreto nº 1.775/96, já declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 24.045, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Os interessados tiveram a oportunidade de se habilitar no processo administrativo de demarcação das terras indígenas, como de fato assim procederam o Estado de Roraima, o Município de Normandia, os pretensos posseiros e comunidades indígenas, estas por meio de petições, cartas e prestação de informações. Observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3.2. Os dados e peças de caráter antropológico foram revelados e subscritos por profissionais de reconhecidas qualificação científica e se dotaram de todos os elementos exigidos pela Constituição e pelo Direito infraconstitucional para a demarcação de terras indígenas, não sendo obrigatória a subscrição do laudo por todos os integrantes do grupo técnico (Decretos nos 22/91 e 1.775/96).** 3.3. A demarcação administrativa, homologada pelo Presidente da República, é "ato estatal que se reveste da presunção juris tantum de legitimidade e de veracidade" (RE 183.188, da relatoria do ministro Celso de Mello), além de se revestir de natureza declaratória e força auto-executória. Não comprovação das fraudes alegadas pelo autor popular e seu originário assistente."

Quanto à necessidade de citação dos interessados para participar do processo demarcatório, ressalte-se que o procedimento estabelecido pelo Decreto nº 1.775/1996 não prevê a citação dos detentores de títulos de domínio ou possessórios para integrar o processo administrativo na fase inicial, obedecendo ao contraditório diferido já reconhecido como não atentatório ao princípio constitucional da ampla defesa.

Com efeito, previu-se a participação da comunidade indígena em todas as fases do processo (art. 2º, §2º), uma vez que a demarcação deve

identificar os elementos de tradicionalidade, sendo imperiosa a realização de entrevistas e oitiva dos índios.

De outra parte, o §8º do artigo 2º do Decreto nº 1.775/1996 prevê que "*desde o início do procedimento demarcatório até noventa dias após a publicação de que trata o parágrafo anterior, poderão os Estados e municípios em que se localize a área sob demarcação e demais interessados manifestar-se*", mas não prevê qualquer espécie de notificação ou citação específica. Ao revés, o §7º do mesmo dispositivo prevê apenas a necessidade de publicação do relatório aprovado pelo titular da FUNAI no Diário Oficial da União, no órgão oficial de imprensa do Estado no qual se localizar a área a ser demarcada, bem como a afixação nas sedes das Prefeituras envolvidas. E, em análise ao procedimento, depreendo que referido relatório foi publicado no DOU de 11.11.1999, e no DOESC de 03.12.1999, iniciando-se aí o prazo de 90 dias para impugnação, que foi observado por inúmeros proprietários e pelo Estado de Santa Catarina, como demonstram as impugnações apreciadas pelo Ministério da Justiça (apensos 32 e ss.).

Da mesma forma, em relação ao levantamento fundiário realizado pelo órgão indigenista, depreende-se inexistir irregularidade; a integralidade das propriedades não foi vistoriada porque os próprios titulares teriam se recusado a prestar as informações devidas, como informado na rejeição das impugnações à demarcação:

> "**O levantamento fundiário dos ocupantes não-índios incidentes dentro da área identificadas e delimitada, como ficou claro no relatório, não foi procedido em sua totalidade, por recusa dos mesmos em fornecer as informações devidas. Quanto aos levantamentos realizados, eles foram autorizados pelos ocupantes que inclusive forneceram escrituras e registros cartoriais, bem como croquis das áreas de suas propriedades, como é o caso das áreas florestadas**."

Ademais, foi realizado levantamento fundiário bastante extenso da região (apenso 56 e ss.), a possibilitar à autoridade do órgão indigenista a tomada de decisão de forma fundamentada. O levantamento definitivo

de todas as benfeitorias será realizado se reconhecida a validade de todo o processo demarcatório, na fase da demarcação física da área, inexistindo prejuízos aos proprietários, se reconhecida a necessidade de extrusão da terra tradicional indígena.

Sustentam ainda os requerentes ter havido manifesta parcialidade do laudo antropológico, que somente levou em consideração as alegações da comunidade indígena em sua elaboração.

No ponto, também, não logrou êxito a parte autora em demonstrar a alegada parcialidade do laudo, tão somente por ter concordado com as reivindicações da comunidade indígena interessada. Ressalto, como abaixo explicitarei mais minudentemente, que consiste o trabalho técnico antropológico em prova essencial à demonstração da tradicionalidade da ocupação indígena, e faz-se imperiosa a participação da comunidade, a fim de demonstrar suas alegações, provar o modo de vida que sustenta desenvolver, enfim, uma vez que a demarcação protege o patrimônio da União, mas delimita a terra em usufruto exclusivo e permanente, não faz sentido que os índios não participem ativamente do processo. Essa circunstância não tem o condão de negar ao laudo de natureza científica valor para a comprovação de que aquela área é de ocupação tradicional, nem pode, sem comprovação inequívoca por parte de quem alega, servir para contestar-se a imparcialidade da equipe de campo e, especialmente, do antropólogo responsável pelo trabalho.

A prolação de conclusão contrária a seu interesse, a qual é posteriormente submetida a contraditório regular dentro do processo demarcatório e anterior à decisão do titular do órgão indigenista e do Ministro da Justiça, não gera parcialidade do laudo, mormente se nenhuma prova foi produzida pelos autores nesse sentido.

Rejeito, portanto, a alegação.

Finalmente, sustentam os requerentes ter havido evidente desvio de finalidade na conclusão do processo demarcatório, uma vez que o grupo técnico foi instituído apenas para a aferir os limites fixados pelo Decreto 015/1926, mas a área demarcada foi maior do que aquela a que a Portaria 418/PRES/95 determinou-se a analisar.

cópia

Nada obstante, depreendo inexistir a mácula aventada pelos autores.

Tendo sido constituído grupo para estudo da efetiva verificação da tradicionalidade de área, e tendo o relatório de identificação constatado que, em verdade, a terra indígena tinha delimitação maior que aquela fixada pelo Decreto Estadual nº 015/26 – além de compreender que tal ato normativo seria inconstitucional diante de todo o histórico de expulsões e da natureza da terra indisponível à concessão estadual – não depreendo existir a nulidade apontada pelos requerentes.

De fato, nulidade haveria se, apresentando-se os estudos conclusivos da existência de área tradicional indígena de maior amplitude, fosse limitada a demarcação para obedecer a ato estadual de constitucionalidade e legalidade questionáveis (diante do entendimento representado no laudo no sentido de que a área não era devoluta) e deixasse de respeitar o disposto no artigo 231 do texto constitucional.

A verificação da higidez material das conclusões do laudo serão verificadas a seguir, mas não visualizo desvio de finalidade no reconhecimento da integralidade da terra considerada como de ocupação tradicional indígena, a despeito da ideia de, inicialmente, verificar a possibilidade de expansão da área para atender o Decreto Estadual nº 015/95.

Logo, rejeito as alegações de vícios formais no complexo procedimento demarcatório ora analisado.

Passo à análise das demais alegações dos Autores, de ordem material.

Cópia

<u>Da constatação da tradicionalidade da ocupação indígena</u>

Os autores rebatem a tradicionalidade da posse indígena na região, argumentando pela ausência dos requisitos do artigo 231 da Constituição Federal, quanto ao território proposto para ampliação da reserva indígena, pois a área é habitada há décadas pelos agricultores, que receberam suas terras do Estado, em razão da colonização incentivada no

interior de Santa Catarina. Assim, afirmam que a pretensão de ampliação da terra indígena demarcada não se justifica, uma vez que não possuem posse atual e permanente da área, mas buscam a recuperação de terras perdidas no passado, aplicando-se, portanto, a Súmula 650 do STF.

Em análise das alegações dos requerentes, cumpre perquirir, prefacialmente, o que é a posse indígena nos termos do artigo 231 do texto constitucional.

Esta Corte já assentou que a posse indígena difere-se frontalmente da posse civil, não sendo portanto regulada pela legislação privatística vigente, mas sim pelas previsões constitucionais configuradoras do direito territorial indígena.

É como delineou a questão o acórdão prolatado na Pet nº 3.388:

> **"11.3. O marco da concreta abrangência fundiária e da finalidade prática da ocupação tradicional. Áreas indígenas são demarcadas para servir concretamente de habitação permanente dos índios de uma determinada etnia, de par com as terras utilizadas para suas atividades produtivas, mais as "imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar" e ainda aquelas que se revelarem "necessárias à reprodução física e cultural" de cada qual das comunidades étnico-indígenas, "segundo seus usos, costumes e tradições" (usos, costumes e tradições deles, indígenas, e não usos, costumes e tradições dos não-índios). Terra indígena, no imaginário coletivo aborígine, não é um simples objeto de direito, mas ganha a dimensão de verdadeiro ente ou ser que resume em si toda ancestralidade, toda coetaneidade e toda posteridade de uma etnia. Donde a proibição constitucional de se remover os índios das terras por eles tradicionalmente ocupadas, assim como o reconhecimento do direito a uma posse permanente e usufruto exclusivo, de parelha com a regra de que todas essas terras "são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis" (§ 4º do art. 231 da Constituição Federal). O que termina por fazer desse tipo tradicional de posse um heterodoxo instituto de**

Cópia

> **Direito Constitucional, e não uma ortodoxa figura de Direito Civil. Donde a clara intelecção de que OS ARTIGOS 231 E 232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONSTITUEM UM COMPLETO ESTATUTO JURÍDICO DA CAUSA INDÍGENA."**

A posse privada, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, pode ser compreendida como uma projeção do próprio direito de propriedade, em especial porque usualmente o possuidor é também o portador do título de domínio do bem. É um direito patrimonial particular em regra transmissível que recai sobre uma coisa ou um bem, como assim operam os direitos reais, e tem finalidade eminentemente econômica, na dinâmica de circulação do mercado como objeto de venda, doação, permuta, 'et coetera', devidamente funcionalizado como um reflexo do exercício dos poderes proprietários, conforme hermenêutica do artigo 5º, inciso XXIII da Constituição da República.

No caso das terras indígenas, a função econômica da terra se liga à conservação das condições de sobrevivência e do modo de vida indígena, mas não funciona como mercadoria para essas comunidades. A manutenção do *habitat* indígena não se resume ao conjunto de ocas, mas sim, como dispõe o artigo 231 da Constituição da República, valendo a pena rememorar a exata dicção constitucional:

> "Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
>
> § 1º **São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições**.
>
> § 2º **As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios**

> **destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes**.
>
> § 3º **O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei**.
>
> § 4º **As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis**.
>
> § 5º **É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco**.
>
> § 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.
>
> § 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º."

A posse indígena, portanto, não se iguala à posse civil; ela deságua na própria formação da identidade das comunidade dos índios, e não se qualifica como mera aquisição do direito ao uso da terra. Como descreve Edílson Vitorelli:

> "**A posse indígena, portanto, embora variável de comunidade para comunidade, se vincula à vivência cultural, às crenças, rituais, aos mortos enterrados e demais traços que**

> **caracterizam indiscutivelmente as tradições indígenas, sendo que é exatamente nesse ponto que se distingue da posse civil, que exige a caracterização de um poder de fato sobre a coisa. Em uma comparação talvez imprecisa, é como se a posse da terra, para o índio, fosse um direito da personalidade, e não um direito patrimonial**."
>
> (VITORELLI, Edílson. Estatuto do Índio: Lei 6.001/1973. 3.ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 189)

Portanto, não é o conceito de posse civil que deve guiar a delimitação da extensão de terras necessárias à ocupação tradicional dos índios, mas sim a investigação da posse indígena, com todos os seus atributos.

Em definição já clássica, José Afonso da Silva assim define as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios:

> "**A base do conceito acha-se no art. 231, §1º, fundado em quatro condições, todas necessárias e nenhuma suficiente sozinha, a saber: (a) serem por eles *habitadas em caráter permanente* ; (b) serem por eles *utilizadas para suas atividades produtivas* ; (c) serem *imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar* ; (d) serem *necessários à sua reprodução física cultural* – tudo segundo seus usos, costumes e tradições.** De sorte que não se vai tentar definir o que é *habitação permanente*, o que é *modo de utilização*, *atividade produtiva*, ou qualquer das condições ou termos que as compõem, segundo a visão civilizada, a visão do modo de produção capitalista ou socialista, a visão do bem-estar do nosso gosto; mas segundo o modo de ser deles, índios, da cultura deles.
>
> 'Terras tradicionalmente ocupadas' não se revela, aí, uma relação temporal. Se recorrermos ao Alvará de 1.4.1680, que reconhecia aos índios as terras onde estavam e as terras que ocupavam no sertão, veremos que a expressão 'ocupadas tradicionalmente' não significa ocupação imemorial. **Não quer dizer, pois, *terras imemorialmente ocupadas* , ou seja: terras**

Cópia

> **que eles estariam ocupando desde épocas remotas, que já se perderam na memória, e, assim, somente estas seriam as terras deles. Não se trata, absolutamente, de *posse* ou *prescrição imemorial* , como se a ocupação indígena nesta se legitimasse, e dela se originassem seus direitos sobre as terras, como uma forma de *usucapião imemorial* , do qual emanariam os direitos dos índios sobre as terras por eles ocupadas – porque isso, além do mais, é incompatível com o reconhecimento constitucional dos direitos originários sobre elas**.
>
> Nem 'tradicionalmente' nem 'posse permanente' são empregados em função de *usucapião imemorial* em favor dos índios, como eventual título substantivo que prevaleça sobre títulos anteriores. Primeiro porque não já títulos anteriores a seus direitos originários. Segundo, porque usucapião é modo de aquisição da propriedade, e esta não se imputa aos índios, mas à União, a outro título. Terceiro, porque os direitos dos índios sobre suas terras assentam em outra fonte: o *indigenato* (infra).
>
> **O 'tradicionalmente' refere-se não a uma circunstância temporal, mas ao *modo tradicional* de os índios ocuparem e utilizarem as terras e ao modo tradicional de produção – enfim, ao modo tradicional de como eles se relacionam com a terra, já que há comunidades mais estáveis, outras menos estáveis, e as que têm espaços mais amplos pelos quais se deslocam etc.** Daí dizer-se que tudo se realize segundo seus usos, costumes e tradições."
>
> (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 8.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 889-890)

A fim de localizar, delimitar e definir todos esses elementos, conjuntamente e sem nenhuma preponderância de um sobre os demais, como já se argumentou acima, o Decreto nº 1.775/1996 elege o laudo antropológico como instrumento para a demonstração de que a área é de posse tradicional indígena.

E, de fato, se a tradicionalidade refere-se ao modo de ocupação da terra, de acordo com os costumes, usos e tradições da comunidade

indígena, se a ligação com a terra faz parte da própria definição da identidade enquanto índio e enquanto comunidade indígena, apenas um trabalho técnico, a levantar as características históricas, etnográficas, sociológicas e ambientais da ocupação conseguirá determinar se há ou não o cumprimento do disposto no artigo 231, §1º do texto constitucional.

No julgamento da Ação Cível Originária nº 362, essa necessidade do estudo antropológico a embasar as conclusões pela tradicionalidade da ocupação indígena já foi ressaltada.

Para o i. Ministro Roberto Barroso:

> *"A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios fundamenta-se em trabalhos antropológicos de qualificação reconhecida, sendo sua iniciativa e orientação de competência da FUNAI. Sendo assim, por uma questão de capacidade institucional, tendo sido respeitado o devido processo legal e não sendo essa uma situação de certeza negativa sobre a ocupação indígena, deve haver deferência do Judiciário à análise técnica das autoridades competentes".*

Também compreende dessa forma o i. Ministro Ricardo Lewandowski:

> *"Quero rapidamente, eminente Presidente, pontuar um aspecto que é recorrente nas discussões que temos quando tratamos de assuntos indígenas. Não raro, diria, até muito comum, serem os laudos antropológicos desqualificados, imputando-lhes a característica de que são mera literatura. Reafirmo aqui - e, aliás, ontem, essa minha convicção foi fortalecida pela presença de duas eminentes professoras da Universidade de Brasília, que lidavam com a questão indígena, que são antropólogas por profissão, e que me convenceram mais uma vez, e nem precisariam, porque tenho também uma formação em Ciências Sociais e dediquei dois anos da minha vida ao estudo da antropologia, primeiro física, depois, cultural – e afirmar que a Antropologia é, sim, uma ciência. É uma Ciência porque tem método próprio, um objeto específico e baseia suas conclusões em dados empíricos.*

Cópia

> *Ao nos debruçarmos sobre estes laudos antropológicos, que integram esses dois feitos, verificamos que são dados antropológicos elaborados segundo os cânones científicos, porque estão fundados em documentos, mapas e provas testemunhais. Portanto, são laudos, do ponto de vista técnico, absolutamente impecáveis -, aliás, foram realizados por determinação de Vossa Excelência, em boa hora, Ministro Marco Aurélio - e que a meu ver, resolvem a controvérsia fática, como disse o eminente Procurador-Geral da República, de maneira absolutamente definitiva.*"

A definição da tradicionalidade da ocupação indígena, da manutenção dos laços culturais, espirituais e ambientais com a área considerada, portanto, não envolve apenas uma conceituação jurídica, mas exige demonstração realizada por laudo técnico, nos termos do Decreto nº 1.776/1996, com a participação da comunidade afetada, e também da sociedade envolvida, nos termos ali delineados.

Assim, abarcar o pluralismo que compreende a distinção dos modos de vida indígena, das várias etnias e comunidades com terras ainda por demarcar, exige que o julgador valore o trabalho técnico antropológico como sendo aquele a demonstrar a tradicionalidade da posse indígena, a ligação com o território, de acordo com seus usos, costumes e tradições, de modo a perfazer os requisitos do §1º do artigo 231 da Constituição Federal.

E, de fato, o laudo antropológico elaborado no bojo do procedimento demarcatório demonstrou a presença dos requisitos do artigo 231:

> "Do exposto até o momento, e, com o propósito de encaminhar solução adequada às conclusões do reestudo, tecemos as seguintes considerações a fim de resguardar as determinações constitucionais vigentes e atender aos direitos reivindicados pelos povos indígenas Xokleng, Kaingang e Guarani, habitantes na TI:
>
> **A perícia topográfica realizada na linha demarcatória da TI e estendida às áreas de terras reivindicadas revelou, de forma cabal, a usurpação do território reconhecido e**

reivindicado pelos indígenas. Os resultados alcançados pelo GT demonstram os tipos de modalidade expropriatória sofrida pelos Xokleng tanto na área de terra reservada pelo estado como na totalidade da Terra Indígena, entendida como fração histórica e recorte do território de ocupação tradicional no sul do Brasil.

Nesses termos, comprovamos em campo a diminuição da área reservada pelo Decreto de 1926, tendo sido extraído da atual TI a área de terras situada entre os, rios Denecke e Prata. Com relação ao Acordo de 1952, os Levantamentos Periciais confirmaram a não inclusão da área de terras situada entre a barra do rio Engano (arroio Perdido nas Cartas Topográficas atuais) e o Bom Sucesso na porção norte da TI. Igualmente constatou-se a não devolução do lote 1701, no limite sul da área, para os indígenas conforme previsto no acordo supra.

Em relação á área de ocupação tradicional - o território assumido politicamente - a Terra Indígena - pelos Xokleng confinados atualmente na TI, os Levantamentos Periciais detectaram a expropriação por agencias/agentes de contato não-índios da área de terras situada na Serra da Abelha/Barra da Prata, espaços considerados pelos indígenas como de relevância para sua reprodução biológica e cultural.

Essa área de terras tradicionalmente ocupada que está sendo reivindicada pelos indígenas e da qual não podem abrir mão, é considerada por eles como fundamental para sua existência como grupo étnico diferenciado presente no interior da sociedade nacional.

As discrepâncias encontradas ao longo do trabalho de perícia topográfica apresentam-se como exemplo objetivo de expropriação da terra indígena por terceiros, leia-se o SPI, através da 7ª Inspetoria, o estado de Santa Catarina, através da DTC, e particulares. Indiscutivelmente existem discrepâncias consideráveis em relação ao decreto de 1926, com a retirada da área da Barra da Prata, e ao Acordo de 1952, com a não inclusão dentro dos limites da Terra Indígena da região do Bom Sucesso, no norte, e do lote 1701, no extremo sul da área.

Na realidade, tal situação iniciou em 1926, quando foi reservada, de dentro da extensa área de ocupação tradicional, uma pequena área para confinamento dos Xokleng. Já, em 1956, quando da demarcação procedida pelo SPI, que ao invés de sair com uma linha seca a oeste da TI, tomando como referência a barra do rio Engano [que nas Cartas Topográficas atuais aparece sob a denominação de ribeirão Perdido], saiu da barra do rio Denecke, que fica aproximadamente 700 metros à jusante daquele. Igualmente a demarcação física, efetuada pelo SPI não tomou o rumo nascente verdadeiro, isto é, rumo às nascentes do rio Engano. De outro lado, com aquele acordo, o próprio estado expropriou a área da Barra da Prata, concedendo títulos de propriedade a não índios.

No limite leste comprovamos as suspeitas levantadas por membros da aldeia Bugio de que parte de um reflorestamento de pinos invade a Terra Indígena, tomando-se por base os limites territoriais atuais. A pericia apontou um avanço de cerca de 30 hectares. Além disso, nessa região do Rio Wiegand permanecem fortes indícios de que os limites antigos reconhecidos pela comunidade vão além daqueles que foram estabelecidos pelo Decreto de 1926 e ratificados no Acordo de 1952. Conforme o depoimento de vários indígenas, a divisa reconhecida pelos Xokleng era o rio Wiegand, e não a serra, extremando com os lotes da linha colonial do supracitado rio.

Por fim, indicamos que a Terra Indígena La Klãnõ reivindicada pelos Xokleng, identificada e delimitada pelo Grupo Técnico de trabalho, garante minimamente a reprodução física e sócio-cultural dos povos Xokleng, Kaingang e Guarani, em consonância com o respeito aos preceitos constitucionais vigentes. Registre-se, contudo, que o processo de constituição de uma Terra Indígena é por definição conjuntural. (cf. explicitamos no tópico 7 .1. do presente Laudo). Nestes termos, reiteramos que as frações de áreas de terras da Serra Alta dos Índios, Rio Krauel, Caxeta, Moema e a Serra do Taió são espaços tradicionais dos Xokleng não reivindicados na presente identificação e delimitação da Terra Indígena La

Cópia

Klãnõ.

Em termos conclusivos, podemos afirmar que os levantamentos periciais históricos e antropológicos efetuados demonstraram que os Xokleng ocupavam tradicionalmente as terras situadas no Bom Sucesso, Barra da Prata, Serra da Abelha, Varaneira e Palmerinha. A reivindicação indígena abarca tais áreas de terras, as quais abrangem um território de 37.108,3568 hectares, com um perímetro de 109.775.32 M."

"Conforme suficientemente explicitado no Laudo Antropológico de Identificação e Delimitação os Xokleng possuíam uma área de terras maior do que esta que está sendo reivindicada pelos povos Xokleng, Guarani e Kaíngang habitantes na TI La Klãnõ. Comprovadamente exerciam ocupação permanente e tradicional nesse território que compreende as terras situadas no Alto Vale do Itajaí. Este povo indígena exercia a ocupação tradicional e permanente exatamente dentro do que atualmente determinam as quatro condições básicas do Art. 231 da Constituição Federal brasileira, que caracterizam uma Terra Indígena, quais sejam: la. - serem habitadas em caráter permanente; 2a. - serem terras utilizadas para desenvolvimento de suas atividades produtivas; 3a- serem terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem estar; 4a. - serem terras necessárias à sua preservação física e cultural. Essas quatro condições "todas necessárias e nenhuma suficiente sozinha" (SILVA, 1993:47).

Contudo, não há que se falar que nas terras pretendidas pelos Xokleng na Serra da abelha, Barra da Prata, Varaneira, Palmerinha e Bom Sucesso não haveria a ocupação permanente indígena. Primeiro porque, em relação aos povos indígenas, não se pode falar em ocupação permanente a partir de preceitos do direito civilista patrimonial brasileiro, tendo inclusive sido apontado no Laudo de Identificação e Delimitação da TI La Klãño, que os indígenas continuam, ao seu modo, ocupando essas terras na medida exata em que acontecem deslocamentos de indígenas às áreas supracitadas

> **e, mais importante, à memória coletiva grupal essas terras continuam a lhes pertencer de acordo com suas tradicionalidades**.
>
> (…)
>
> **Segundo porque, como também ficou suficientemente evidenciado pelos levantamentos periciais procedidos pelo GT, os indígenas perderam a posse material dessas terras em questão, pela violência, contra sua vontade. Ressalte-se que esse esbulho do território tradicional Xokleng, que resultou em uma diminuta fração de 14.084 hectares, deu-se através de vários mecanismos expropriatórios, todos eles violentos, ilegais e inconstitucionais. Além disso, as atuais posses de não-índios sobre essas terras também não podem ser convalidadas. Primeiro porque nunca foram tidas mansa e pacificamente, pois os índios, além de expulsos, nunca desistiram dessas terras, tendo inúmeras vezes pleiteado, junto aos organismos competentes, principalmente SPI e FUNAI, a devolução desses territórios. Segundo porque os direitos indígenas são imprescritíveis**.
>
> Mas ainda há que se evocar outra fundamentação para comprovar que os Xokleng não perderam os direitos sobre essas terras reivindicadas. Tourinho Neto reforça que: 'As terras ocupadas tradicionalmente pelos índios 'destinam-se a sua posse permanente', impõe o § 2° do art. 231 da Constituição de 1988. A *permanência* exigida pelas Constituições de 1934, 1937 e 1946 refere-se ao passado. A exigida pelas Constituições de 1967, 1969 e 1988, ao futuro. Observe-se que as Constituições passadas impunham respeito à posse das terras onde os índios se achavam permanentemente localizados. Na de 1988, lê-se 'as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente'. Nas de 1967 e de 1969, os índios têm a posse permanente das terras que habitam" (NETO, 1993:22, grifo do autor)."

Referido laudo foi corroborado pela perícia judicial antropológica, que também identificou a tradicionalidade da ocupação na área:

> "Portanto, **é possível concluir que toda a área de expansão da TI foi ocupada pelos indígenas, utilizada em suas atividades produtivas de caça, coleta e agricultura, embora esta ocupe menor destaque em suas atividades econômicas, e esta situação se alterou gradualmente à medida em que as empresas madeireiras e as famílias agricultoras intensificaram sua presença**.
>
> **Destaco a ação do governo do Estado de Santa Catarina e do SPI que com o Decreto 15 de 1926 restringiram pela metade o tamanho da terra inicialmente utilizada pela Comunidade Indígena, deixando fora da TI as porções melhores, mais planas e onde e encontravam os pinheirais e ainda, posteriormente, em 1952, excluindo 6 mil hectares da terra indígena que já havia sido decretada.**
>
> **O Juízo questiona se foram habitadas em caráter permanente. Esclareço que o conceito de habitação permanente carrega um referencial cultural ocidental de moradia fixa que não é possível aplicar ao modo de vida indígena praticado até a década de 1950. Mesmo nas condições atuais de aldeamento, a comunidade indígena LaKlãno manifesta um padrão de mobilidade habitacional, interna e externamente à TI, bastante elevado para os critérios da cultura ocidental, conforme foi concluído pelo trabalho de Loch, 2004.**
>
> **Se o postulado da ocupação permanente tivesse como referência a necessidade de estar ocupando no ano de 1988 a totalidade do território identificado como tradicional, ignoraria a história de invasões e expropriações recentes de terras indígenas, porém anteriores àquela data, em contexto de violência física e burocrática, ainda que sob a justificativa da existência de reduzido número indígenas, como foi o caso da TI IbiramaLaKlãno**."

Assim, os laudos antropológicos encartados aos autos demonstram a ocorrência da posse indígena, realçando a distinção desta com a posse

civil, pois a terra para os índios não possui a mesma finalidade primordialmente econômica, mas serve de *habitat*, de fonte de alimento e de exercício de sua cultura; reconheceram, portanto, a presença dos requisitos contidos no artigo 231 do texto constitucional.

Da não configuração da área como terra devoluta

Os autores e também o Estado de Santa Catarina, na qualidade de litisconsorte ativo, sustentam que as terras cuja demarcação se pretende, eram devolutas, e foram objeto de concessão pelo Estado às companhias colonizadoras, no legítimo exercício de sua competência.

No entanto, como já me manifestei em outras oportunidades, terra indígena não é terra devoluta e, portanto, não poderiam ser tituladas pelos entes estaduais, pois não ingressaram em seu patrimônio.

De fato, desde o Brasil colônia, é possível afirmar a existência de atos normativos a reconhecer os direitos territoriais dos índios às terras, mesmo que sem a expedição de qualquer título possessório, uma vez tratar-se de direito congênito, como primeiros ocupantes, daquelas áreas.

Como escreve Manuela Carneiro da Cunha:

> "Nas leis portuguesas para o Brasil, a soberania indígena e o direito dos índios aos territórios que ocupam é frequentemente reconhecida: trata-se, como se sabe, de um reconhecimento de jure que mil estratagemas tentam contornar na prática; mas um tal reconhecimento legal mostra pelo menos a consciência e a má consciência da Coroa acerca dos direitos indígenas.
>
> Assim, as cartas régias de julho de 1609 e de 10 de setembro de 1611, promulgadas por Filipe III, afirmam o pleno domínio dos índios sobre seus territórios e sobre as terras que lhes são alocadas nos aldeamento:
>
> 'os gentios são senhores de suas fazendas nas povoações, como o são na Serra, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre elas se lhes fazer moléstia ou injustiça alguma; nem poderão ser

> mudados contra suas vontades das capitanias e lugares que lhes forem ordenados, salvo quando eles livremente o quiserem fazer (…).'"
>
> (CUNHA, Manuela Carneiro da. *Terra Indígena: história da doutrina e da legislação*. In: CUNHA, Manuela Carneiro da; BARBOSA, Samuel (orgs). Direito dos povos indígenas em disputa. São Paulo: Editora Unesp, 2018, p. 285)

Posteriormente, o Alvará Régio de 1680 também reconhecia, de forma mais clara, a posse e o domínio sobre as terras que os *gentios* ocupavam:

> **"[...] E para que os ditos Gentios, que assim decerem, e os mais, que há de presente, melhor se conservem nas Aldeias: hey por bem que senhores de suas fazendas, como o são no Sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhe fazer moléstia. E o Governador com parecer dos ditos Religiosos assinará aos que descerem do Sertão, lugares convenientes para neles lavrarem, e cultivarem, e não poderão ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro, ou tributo algum das ditas terras, que ainda estejão dados em Sesmarias e pessoas particulares, porque na concessão destas se reserva sempre o prejuízo de terceiro, e muito mais se entende, e quero que se entenda ser reservado o prejuízo, e direito os Índios, primários e naturais senhores delas."**

Nem mesmo a Lei de Terras, de nº 601/1850, que destinava-se a estabelecer requisitos para a legitimação da posse privada de terras públicas no Brasil, infirmou a posse congênita indígena sobre as terras que ocupavam. Para tanto, referido diploma inaugurou o conceito de terras devolutas, definidas em seu artigo 3º como:

> "Art. 3º São terras devolutas:
>
> § 1º As que não se acharem applicadas a algum uso

> publico nacional, provincial, ou municipal.
>
> § 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta do cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura.
>
> § 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei.
>
> § 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se fundarem em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei."

Por sua vez, o artigo 12 da referida lei determinava a reserva de terras daquelas consideradas devolutas – ou seja, disponíveis para apropriação particular – as terras destinadas à colonização dos índios:

> "Art. 12. O Governo reservará das terras devolutas as que julgar necessarias: 1º, para a colonisação dos indigenas; 2º, para a fundação de povoações, abertura de estradas, e quaesquer outras servidões, e assento de estabelecimentos publicos: 3º, para a construção naval."

Mais adiante, a Constituição de 1891, ao ensejo da inauguração da República Brasileira e da organização do sistema federativo, conferiu aos Estados as terras devolutas localizadas em seus territórios, nos seguintes termos:

> "Art. 64 - *Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais*."

Desses diplomas legislativos, depreende-se que o direito dos indígenas à posse e uso das terras que ocupavam não só não restou

infirmado pela Lei de Terras acima citada, como veio também assegurado pelo disposto do artigo 24, § 1º do Decreto nº 1318/1854, que regulamentou referida lei, pois entende que a posse é legitimada ao primeiro ocupante, e já se reconhecia o direito originário dos indígenas às terras em sua posse.

Tratava-se, nas palavras de João Mendes Jr., do reconhecimento do *indigenato*, ou seja, de que os índios eram os ocupantes primeiros das terras, e sua posse não estava sujeita à legitimação pelo ordenamento jurídico, pois não se tratava de aquisição de um direito, mas apenas da declaração de sua existência:

> "Não quero chegar até o ponto de affirmar, como P.J. Proudhon, nos *Essais d'une philos. populaire*, que – 'o *indigenato* é a *unica* verdadeira fonte jurídica da posse territorial'; mas, sem desconhecer as outras fontes, já os philosophos gregos affirmavam que **o *indigenato* é um título *congenito* , ao passo que a *occupação* é um título *adquirido*. Comquanto o *indigenato* não seja o *unica* verdadeira fonte jurídica da posse territorial, todos reconhecem que é, na phrase do Alv. de 1º de Abril de 1680, 'a primaria, naturalmente e virtualmente reservada', ou, na phrase de Aristoteles (Polit., I, n. 8), - 'um *estado* em que se acha cada ser a partir do momento do seu nascimento'. Por conseguinte, o *indigenato* não é um facto dependente de legitimação, ao passo que a *occupação* , como facto posterior, depende de requisitos que a legitimem**."
>
> (MENDES JUNIOR, João. Os indígenas do Brazil, seus direitos individuaes e políticos. São Paulo: Hennies Irmãos,1912, p. 58.)

A Constituição Federal de 1934 foi a primeira a consagrar o direito dos índios à posse de suas terras, disposição repetida em todos os textos constitucionais posteriores, sendo entendimento pacífico na doutrina que esse reconhecimento constitucional operou a nulidade de pleno direito de qualquer ato de transmissão da posse ou da propriedade dessas áreas a terceiros.

Uma vez mais, é pertinente a citação de Manuela Carneiro da Cunha:

> "É na Assembleia Constituinte de 1934 que, pela primeira vez, a questão da terra indígena passa a ser matéria constitucional. Não constava dispositivo algum sobre índios nem no projeto do governo, o chamado Projeto do Itamaraty, nem no substitutivo da Comissão dos 26, composto de um membro da bancada de cada estado, do Distrito Federal, do Acre, além dos representantes dos empregados, empregadores, funcionários e das profissões liberais. A primeira emenda apresentada tem origem na bancada amazonense, e foi apresentada a 21 de dezembro de 1933, pelo deputado Álvaro Maia e mais três deputados, sob o número 1.193. Vinha assim redigida: 'A União, os Estados, ou os municípios respeitarão a posse dos indígenas sobre as terras onde estiverem localizados, tudo nos termos da legislação federal sobre o assunto'.
>
> **A justificação da emenda 'provava que ela se fundamentava nas leis referentes aos indígenas, consubstanciadas desde o Império à República' e acrescentava**:
>
> '**Temos regiões habitadas por centenas de tribos, a que pertencem milhares de indivíduos. Não é admissível que sejam concedidos, retalhados os lotes, às vezes cultivados e expulsos para o interior das selvas. Dessas atitudes desumanas surgem lutas que redundam em dificuldade à catequese. A emenda consubstancia a legislação federal sobre o assunto, colocando-a, porém, sob a segurança maior de um dispositivo constitucional**'."
>
> (CUNHA, Manuela Carneiro da. *Terra Indígena: história da doutrina e da legislação*. In: CUNHA, Manuela Carneiro da; BARBOSA, Samuel (orgs). Direito dos povos indígenas em disputa. São Paulo: Editora Unesp, 2018, p. 285)

Sobre a posse indígena, assim já se manifestava Pontes de Miranda,

em comentário efetuado à Constituição de 1946, cujo conteúdo era idêntico em relação à tutela dos indígenas na Carta de 1934:

> **"O texto respeita a 'posse' do silvícola, posse a que ainda se exige o pressuposto de localização permanente. O juiz que conhecer de alguma questão de terras deve aplicar o artigo 216, desde que os pressupostos estejam provados pelo silvícola, ou constem dos autos, ainda que alguma das partes ou terceiro exija título de domínio. Desde que há posse e a localização permanente, a terra é do nativo, porque assim o diz a Constituição, e qualquer alienação de terras por parte dos silvícolas, ou em que se achem, permanentemente localizados e com posse, os silvícolas é nula, por infração à Constituição. Aquelas mesmas que forem em virtude do artigo 216 reconhecidas como de posse de tais gentes, não podem ser alienadas. Os juízes não podem expedir mandados contra os silvícolas que tenham posse, e nas terras de que se trata, se localizaram com permanência. A proibição de alienação tem como consequências: a) a nulidade de qualquer ato de disposição incluídos aquêles que só se referem a elementos de direito de propriedade e da posse (uso-fruto, garantia real, locação); b) não há usucapião contra o silvícola, ainda que trintenal; c) as sentenças que adjuquem tais terras a outrem são suscetíveis de recisão, dentro do prazo de preclusão, por infringirem texto constitucional."**
>
> (Comentários à Constituição de 1946, vol. V, 1953, p. 335/336)

Portanto, sendo constatada a ocupação tradicional indígena, não pode a área em comento ser considerada de propriedade alheia, nem mesmo como terra devoluta estadual.

Esta Corte assentou esse posicionamento em diversas oportunidades anteriores à ordem constitucional de 1988, restando já clássico o entendimento esposado pelo Ministro Victor Nunes Leal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 44.585:

"(...) A Constituição Federal diz o seguinte:

'Art. 216: Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde de achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem.'

Aqui não se trata do direito de propriedade comum; o que se reservou foi o território dos índios. Essa área foi transformada num parque indígena, sob a guarda e administração do Serviço de Proteção aos Índios, pois estes não tem a disponibilidade das terras.

O objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam os traços culturais dos antigos habitantes, não só para sobrevivência dessa tribo, como para estudos dos etnólogos e para outros efeitos de natureza cultural ou intelectual.

Não está em jogo, propriamente, um conceito de posse, nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos; trata-se do habitat de um povo.

Se os índios, na data da Constituição Federal, ocupavam determinado território, porque desse território tiravam seus recursos alimentícios, embora sem terem construções ou obras permanentes que testemunhassem posse de acordo com o nosso conceito, essa área, na qual e da qual viviam, era necessária à sua subsistência. Essa área, existente na data da Constituição Federal, é que se mandou respeitar. Se ela foi reduzida por lei posterior; se o Estado a diminuiu de dez mil hectares, amanhã a reduziria em outros dez, depois, mais dez, e poderia acabar confinando os índios a um pequeno trato, até ao terreiro da aldeia, porque ali é que a 'posse' estaria materializada nas malocas.

Não foi isso que a Constituição quis. O que ela determinou foi que, num verdadeiro parque indígena, com todas as características culturais primitivas, pudessem permanecer os índios, vivendo naquele território, porque a tanto equivale dizer que continuariam na posse do mesmo.

Entendo, portanto, que, **embora a demarcação desse território resultasse, originariamente, de uma lei do Estado, a**

Cópia

> **Constituição Federal dispôs sobre o assunto e retirou ao Estado qualquer possibilidade de reduzir a área que, na época da Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada no sentido de utilizada por eles como seu ambiente ecológico**".
>
> (RE 44.585, Tribunal Pleno, DJ em 12/10/1961)

Como acima se apontou, terra indígena não é terra devoluta; assim, as terras não podem ter ingressado no patrimônio estadual e, portanto, não podem ter sido legitimamente transferidas ao patrimônio privado.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

> "EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO X DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BENS DO ESTADO. TERRAS DOS EXTINTOS ALDEAMENTOS INDÍGENAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, I E XI, 22, CAPUT E INCISO I, E 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. EXTINÇÃO OCORRIDA ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1891. ADI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – **A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, reconheceu que as terras dos aldeamentos indígenas que se extinguiram antes da Constituição de 1891, por haverem perdido o caráter de bens destinados a uso especial, passaram à categoria de terras devolutas**. II - Uma vez reconhecidos como terras devolutas, por força do artigo 64 da Constituição de 1891, os aldeamentos extintos transferiram-se ao domínio dos Estados. III – **ADI julgada procedente em parte, para conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo impugnado, a fim de que a sua aplicação fique adstrita aos aldeamentos indígenas extintos antes da edição da primeira Constituição Republicana**.
>
> (ADI 255, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2011, DJe-097 DIVULG 23-05-2011 PUBLIC 24-05-2011 EMENT VOL-02528-01 PP-00001 RTJ VOL-00224-01 PP-00162)

Logo, se a terra não era devoluta, não poderia ter sido loteada pelo Estado de Santa Catarina, nem concedida para fins de colonização, pois se tratava de terra indígena, com proteção legal e, após, constitucional.

Assim, o Decreto Estadual nº 015/1926 não poderia ter reduzido a *área de perambulação indígena* para 20 mil hectares, pois a terra ali não era de domínio estadual, já que configurada pela prova produzida nos presentes autos a posse indígena. Da mesma forma, o Acordo de 1952, entre Estado de Santa Catarina e o SPI, também não se mostrou válido, uma vez que, de acordo com os laudos antropológicos, só foi realizado diante da constatação de que os índios não respeitavam os "limites estabelecidos" pelo Decreto de 1926, sendo necessário reduzir ainda mais a área da qual poderiam usufruir, para liberar mais terras para a transmissão a particulares.

Descabendo falar-se, portanto, em terras devolutas à disposição do ente estadual, compreendo não restar descaracterizada a posse indígena na região em litígio.

Cópia

<u>Do marco temporal</u>

Afirmam ainda os Autores que a comunidade indígena não exerceria a posse atual da área. Posteriormente, pugnam pelo reconhecimento da aplicação ao caso da chamada "teoria do marco temporal".

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.017.365-RG, expressei meu ponto de vista sobre a matéria.

De fato, dentre os anos de 2008 e 2009, esta Corte debruçou-se sobre o caso *Raposa Serra do Sol*, na Pet 3.388, decisão essa que apreciou a questão da demarcação das terras indígenas, em especial no Estado de Roraima, para assegurar aos índios as terras que ocupavam de modo tradicional, bem como seu modo de vida, estabelecendo dezenove condicionantes para o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena em área cuja demarcação se pretende, no propósito de promover

a pacificação dessa grave questão social.

Da leitura da ementa, depreende-se o enorme avanço promovido no sentido da garantia da tutela das comunidades indígenas à luz da Constituição da República:

> "AÇÃO POPULAR. DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. (…) **REVELAÇÃO DO REGIME CONSTITUCIONAL DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO ESTATUTO JURÍDICO DA CAUSA INDÍGENA. A DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS COMO CAPÍTULO AVANÇADO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. INCLUSÃO COMUNITÁRIA PELA VIA DA IDENTIDADE ÉTNICA. VOTO DO RELATOR QUE FAZ AGREGAR AOS RESPECTIVOS FUNDAMENTOS SALVAGUARDAS INSTITUCIONAIS DITADAS PELA SUPERLATIVA IMPORTÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL DA CAUSA**. SALVAGUARDAS AMPLIADAS A PARTIR DE VOTO-VISTA DO MINISTRO MENEZES DIREITO E DESLOCADAS PARA A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO.
>
> (…)
>
> 4. O SIGNIFICADO DO SUBSTANTIVO "ÍNDIOS" NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O substantivo "índios" é usado pela Constituição Federal de 1988 por um modo invariavelmente plural, para exprimir a diferenciação dos aborígenes por numerosas etnias. Propósito constitucional de retratar uma diversidade indígena tanto interétnica quanto intra-étnica. Índios em processo de aculturação permanecem índios para o fim de proteção constitucional. Proteção constitucional que não se limita aos silvícolas, estes, sim, índios ainda em primitivo estádio de habitantes da selva. 5. AS TERRAS INDÍGENAS COMO PARTE ESSENCIAL DO TERRITÓRIO BRASILEIRO. 5.1. As "terras indígenas" versadas pela Constituição Federal de 1988 fazem parte de um território estatal-brasileiro sobre o qual incide, com exclusividade, o Direito nacional. E como tudo o mais que faz parte do domínio

Cópia

de qualquer das pessoas federadas brasileiras, são terras que se submetem unicamente ao primeiro dos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil: a soberania ou "independência nacional" (inciso I do art. 1º da CF). 5.2. Todas as "terras indígenas" são um bem público federal (inciso XI do art. 20 da CF), o que não significa dizer que o ato em si da demarcação extinga ou amesquinhe qualquer unidade federada. Primeiro, porque as unidades federadas pós-Constituição de 1988 já nascem com seu território jungido ao regime constitucional de preexistência dos direitos originários dos índios sobre as terras por eles "tradicionalmente ocupadas". Segundo, porque a titularidade de bens não se confunde com o senhorio de um território político. Nenhuma terra indígena se eleva ao patamar de território político, assim como nenhuma etnia ou comunidade indígena se constitui em unidade federada. Cuida-se, cada etnia indígena, de realidade sóciocultural, e não de natureza político-territorial. 6. NECESSÁRIA LIDERANÇA INSTITUCIONAL DA UNIÃO, SEMPRE QUE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS ATUAREM NO PRÓPRIO INTERIOR DAS TERRAS JÁ DEMARCADAS COMO DE AFETAÇÃO INDÍGENA. A vontade objetiva da Constituição obriga a efetiva presença de todas as pessoas federadas em terras indígenas, desde que em sintonia com o modelo de ocupação por ela concebido, que é de centralidade da União. Modelo de ocupação que tanto preserva a identidade de cada etnia quanto sua abertura para um relacionamento de mútuo proveito com outras etnias indígenas e grupamentos de não índios. A atuação complementar de Estados e Municípios em terras já demarcadas como indígenas há de se fazer, contudo, em regime de concerto com a União e sob a liderança desta. Papel de centralidade institucional desempenhado pela União, que não pode deixar de ser imediatamente coadjuvado pelos próprios índios, suas comunidades e organizações, além da protagonização de tutela e fiscalização do Ministério Público (inciso V do art. 129 e art. 232, ambos da CF). 7. AS TERRAS INDÍGENAS COMO CATEGORIA JURÍDICA DISTINTA DE

Cópia

TERRITÓRIOS INDÍGENAS. O DESABONO CONSTITUCIONAL AOS VOCÁBULOS "POVO", "PAÍS", "TERRITÓRIO", "PÁTRIA" OU "NAÇÃO" INDÍGENA. Somente o "território" enquanto categoria jurídico-política é que se põe como o preciso âmbito espacial de incidência de uma dada Ordem Jurídica soberana, ou autônoma. O substantivo "terras" é termo que assume compostura nitidamente sóciocultural, e não política. A Constituição teve o cuidado de não falar em territórios indígenas, mas, tão-só, em "terras indígenas". A traduzir que os "grupos", "organizações", "populações" ou "comunidades" indígenas não constituem pessoa federada. Não formam circunscrição ou instância espacial que se orne de dimensão política. Daí não se reconhecer a qualquer das organizações sociais indígenas, ao conjunto delas, ou à sua base peculiarmente antropológica a dimensão de instância transnacional. Pelo que nenhuma das comunidades indígenas brasileiras detém estatura normativa para comparecer perante a Ordem Jurídica Internacional como "Nação", "País", "Pátria", "território nacional" ou "povo" independente. Sendo de fácil percepção que todas as vezes em que a Constituição de 1988 tratou de "nacionalidade" e dos demais vocábulos aspeados (País, Pátria, território nacional e povo) foi para se referir ao Brasil por inteiro. 8. A DEMARCAÇÃO COMO COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO. Somente à União, por atos situados na esfera de atuação do Poder Executivo, compete instaurar, sequenciar e concluir formalmente o processo demarcatório das terras indígenas, tanto quanto efetivá-lo materialmente, nada impedindo que o Presidente da República venha a consultar o Conselho de Defesa Nacional (inciso III do § 1º do art. 91 da CF), especialmente se as terras indígenas a demarcar coincidirem com faixa de fronteira. As competências deferidas ao Congresso Nacional, com efeito concreto ou sem densidade normativa, exaurem-se nos fazeres a que se referem o inciso XVI do art. 49 e o § 5º do art. 231, ambos da Constituição Federal. 9. A DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS

Cópia

COMO CAPÍTULO AVANÇADO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. Os arts. 231 e 232 da Constituição Federal são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral de minorias, tendo em vista o protovalor da integração comunitária. Era constitucional compensatória de desvantagens historicamente acumuladas, a se viabilizar por mecanismos oficiais de ações afirmativas. No caso, os índios a desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência econômica para mais eficazmente poderem preservar sua identidade somática, linguística e cultural. Processo de uma aculturação que não se dilui no convívio com os não-índios, pois a aculturação de que trata a Constituição não é perda de identidade étnica, mas somatório de mundividências. Uma soma, e não uma subtração. Ganho, e não perda. Relações interétnicas de mútuo proveito, a caracterizar ganhos culturais incessantemente cumulativos. Concretização constitucional do valor da inclusão comunitária pela via da identidade étnica. 10. O FALSO ANTAGONISMO ENTRE A QUESTÃO INDÍGENA E O DESENVOLVIMENTO. Ao Poder Público de todas as dimensões federativas o que incumbe não é subestimar, e muito menos hostilizar comunidades indígenas brasileiras, mas tirar proveito delas para diversificar o potencial econômico-cultural dos seus territórios (dos entes federativos). O desenvolvimento que se fizer sem ou contra os índios, ali onde eles se encontrarem instalados por modo tradicional, à data da Constituição de 1988, desrespeita o objetivo fundamental do inciso II do art. 3º da Constituição Federal, assecuratório de um tipo de "desenvolvimento nacional" tão ecologicamente equilibrado quanto humanizado e culturalmente diversificado, de modo a incorporar a realidade indígena. 11. **O CONTEÚDO POSITIVO DO ATO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. 11.1. O marco temporal de ocupação. A Constituição Federal trabalhou com data certa -- a data da**

Cópia

promulgação dela própria (5 de outubro de 1988) -- como insubstituível referencial para o dado da ocupação de um determinado espaço geográfico por essa ou aquela etnia aborígene; ou seja, para o reconhecimento, aos índios, dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 11.2. O marco da tradicionalidade da ocupação. É preciso que esse estar coletivamente situado em certo espaço fundiário também ostente o caráter da perdurabilidade, no sentido anímico e psíquico de continuidade etnográfica. A tradicionalidade da posse nativa, no entanto, não se perde onde, ao tempo da promulgação da Lei Maior de 1988, a reocupação apenas não ocorreu por efeito de renitente esbulho por parte de não índios. Caso das "fazendas" situadas na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, cuja ocupação não arrefeceu nos índios sua capacidade de resistência e de afirmação da sua peculiar presença em todo o complexo geográfico da "Raposa Serra do Sol". 11.3. O marco da concreta abrangência fundiária e da finalidade prática da ocupação tradicional. Áreas indígenas são demarcadas para servir concretamente de habitação permanente dos índios de uma determinada etnia, de par com as terras utilizadas para suas atividades produtivas, mais as "imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar" e ainda aquelas que se revelarem "necessárias à reprodução física e cultural" de cada qual das comunidades étnico-indígenas, "segundo seus usos, costumes e tradições" (usos, costumes e tradições deles, indígenas, e não usos, costumes e tradições dos não-índios). Terra indígena, no imaginário coletivo aborígine, não é um simples objeto de direito, mas ganha a dimensão de verdadeiro ente ou ser que resume em si toda ancestralidade, toda coetaneidade e toda posteridade de uma etnia. Donde a proibição constitucional de se remover os índios das terras por eles tradicionalmente ocupadas, assim como o reconhecimento do direito a uma posse permanente e usufruto exclusivo, de parelha com a regra de que todas essas terras "são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis" (§ 4º do

Cópia

art. 231 da Constituição Federal). O que termina por fazer desse tipo tradicional de posse um heterodoxo instituto de Direito Constitucional, e não uma ortodoxa figura de Direito Civil. Donde a clara intelecção de que OS ARTIGOS 231 E 232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONSTITUEM UM COMPLETO ESTATUTO JURÍDICO DA CAUSA INDÍGENA. 11.4. O marco do conceito fundiariamente extensivo do chamado "princípio da proporcionalidade". A Constituição de 1988 faz dos usos, costumes e tradições indígenas o engate lógico para a compreensão, entre outras, das semânticas da posse, da permanência, da habitação, da produção econômica e da reprodução física e cultural das etnias nativas. O próprio conceito do chamado "princípio da proporcionalidade", quando aplicado ao tema da demarcação das terras indígenas, ganha um conteúdo peculiarmente extensivo. 12. DIREITOS "ORIGINÁRIOS". Os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam foram constitucionalmente "reconhecidos", e não simplesmente outorgados, com o que o ato de demarcação se orna de natureza declaratória, e não propriamente constitutiva. Ato declaratório de uma situação jurídica ativa preexistente. Essa a razão de a Carta Magna havê-los chamado de "originários", a traduzir um direito mais antigo do que qualquer outro, de maneira a preponderar sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse em favor de não-índios. Atos, estes, que a própria Constituição declarou como "nulos e extintos" (§ 6º do art. 231 da CF). 13. O MODELO PECULIARMENTE CONTÍNUO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. O modelo de demarcação das terras indígenas é orientado pela ideia de continuidade. Demarcação por fronteiras vivas ou abertas em seu interior, para que se forme um perfil coletivo e se afirme a auto-suficiência econômica de toda uma comunidade usufrutuária. Modelo bem mais serviente da ideia cultural e econômica de abertura de horizontes do que de fechamento em "bolsões", "ilhas", "blocos" ou "clusters", a evitar que se dizime o espírito pela eliminação

Cópia

> progressiva dos elementos de uma dada cultura (etnocídio).(...) 15. A RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA ENTRE TERRAS INDÍGENAS E MEIO AMBIENTE. Há perfeita compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda que estas envolvam áreas de "conservação" e "preservação" ambiental. Essa compatibilidade é que autoriza a dupla afetação, sob a administração do competente órgão de defesa ambiental. (…) 18. FUNDAMENTOS JURÍDICOS E SALVAGUARDAS INSTITUCIONAIS QUE SE COMPLEMENTAM. Voto do relator que faz agregar aos respectivos fundamentos salvaguardas institucionais ditadas pela superlativa importância histórico-cultural da causa. Salvaguardas ampliadas a partir de voto-vista do Ministro Menezes Direito e deslocadas, por iniciativa deste, para a parte dispositiva da decisão. Técnica de decidibilidade que se adota para conferir maior teor de operacionalidade ao acórdão."
>
> (Pet 3388, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-120 DIVULG 30-06-2010 PUBLIC 01-07-2010 EMENT VOL-02408-02 PP-00229 RTJ VOL-00212-01 PP-00049)

No entanto, como decidido no julgamento dos embargos declaratórios opostos ao acórdão da Pet nº 3.388, o Plenário desta Casa assentou a impossibilidade de atribuição de efeitos vinculantes àquela decisão, como se depreende da ementa do referido julgado:

> "Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor, por assistentes, pelo Ministério Público, pelas comunidades indígenas, pelo Estado de Roraima e por terceiros. Recursos inadmitidos, desprovidos, ou parcialmente providos para fins de mero esclarecimento, sem efeitos modificativos. 2. Com o trânsito em julgado do acórdão embargado, todos os processos relacionados à Terra Indígena Raposa Serra do Sol deverão

> adotar as seguintes premissas como necessárias: (i) são válidos a Portaria/MJ nº 534/2005 e o Decreto Presidencial de 15.04.2005, observadas as condições previstas no acórdão; e (ii) a caracterização da área como terra indígena, para os fins dos arts. 20, XI, e 231, da Constituição torna insubsistentes eventuais pretensões possessórias ou dominiais de particulares, salvo no tocante à indenização por benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (CF/88, art. 231, § 6º). 3. As chamadas condições ou condicionantes foram consideradas pressupostos para o reconhecimento da validade da demarcação efetuada. Não apenas por decorrerem, em essência, da própria Constituição, mas também pela necessidade de se explicitarem as diretrizes básicas para o exercício do usufruto indígena, de modo a solucionar de forma efetiva as graves controvérsias existentes na região. Nesse sentido, as condições integram o objeto do que foi decidido e fazem coisa julgada material. Isso significa que a sua incidência na Reserva da Raposa Serra do Sol não poderá ser objeto de questionamento em eventuais novos processos. **4. A decisão proferida em ação popular é desprovida de força vinculante, em sentido técnico. Nesses termos, os fundamentos adotados pela Corte não se estendem, de forma automática, a outros processos em que se discuta matéria similar. Sem prejuízo disso, o acórdão embargado ostenta a força moral e persuasiva de uma decisão da mais alta Corte do País, do que decorre um elevado ônus argumentativo nos casos em se cogite da superação de suas razões**.
>
> (Pet 3388 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 03-02-2014 PUBLIC 04-02-2014 RTJ VOL-00227-01 PP-00057)

Portanto, muito embora decisão tenha a eficácia de coisa julgada material em relação à demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, ela não incide automaticamente às demais demarcações de áreas de ocupação tradicional indígena no País.

Assim, em relação à necessidade da constatação da presença física

da comunidade indígena na área a ser demarcada em 05 de outubro de 1988, com a devida vênia, compreendo não ser a mais consentânea com uma hermenêutica aplicada a direito fundamental dos povos indígenas, além do risco de ineficácia da previsão constitucional, reduzindo as possibilidades de efetivação do direito à posse dos índios, o que não se coaduna com a ordenação constitucional pós redemocratização.

No tópico anterior, já se demonstrou existência de um complexo normativo a proteger a posse indígena, por compreendê-la como um direito congênito – conceito atualizado pelo texto constitucional vigente, que o compreende como um direito originário dos povos indígenas.

O direito dos índios à posse de suas terras veio reconhecido constitucionalmente pela Constituição de 1934, e foi reafirmado pelos textos constitucionais seguintes:

> Constituição de 1934:
>
> Art. 129. Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las.
>
> Constituição de 1937:
>
> Art. 154. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alienação das mesmas.
>
> Constituição de 1946:
>
> Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem.
>
> Constituição de 1967:
>
> Art 186. É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes.

Cópia

> Emenda nº 1/1969:
>
> Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos têrmos que a lei federal determinar, a êles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de tôdas as utilidades nelas existentes.
>
> § 1º Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas.
>
> § 2º A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do Índio.

Cópia

Logo, a proteção constitucional à posse indígena se verifica desde a Carta de 1934, e tem relevo diversas formas e espécies de reconhecimento legislativo da ocupação indígena, desde a época da Colônia.

Tomada a questão pelo aspecto normativo, e considerando que as terras de ocupação indígena, ao menos diante da perspectiva legal, eram protegidas pelo ordenamento jurídico e em especial pelas Constituições desde a de 1934, não se justifica normativamente a "teoria do fato indígena", uma vez que não depreendo da Constituição nenhuma fratura em relação à tutela dos direitos territoriais indígenas, porquanto a simples apropriação dessas terras por parte de particulares, incentivada ou não pelos entes públicos, jamais foi permitida pelos textos constitucionais.

Nessa perspectiva de continuidade, na qual jamais se constitucionalizou a posse dessas terras por parte de terceiros não-índios, não se pode juridicamente inferir do texto atualmente vigente a ilação de que se teriam por legitimados os atos de retirada dos indígenas das terras de posse tradicional.

É certo que, a despeito da proteção constitucional e legislativa, os índios foram, efetivamente, desapossados de grande parte de seu território tradicional, num primeiro momento, para utilização como mão-de-obra, depois para tomada das áreas para ampliação do território

nacional habitado e utilização no agronegócio, como acima já se demonstrou.

Respeitosamente às opiniões contrárias, compreendo, pelas razões acima transcritas, que referido dispositivo constitucional não afasta no tempo presente o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas.

Da configuração do esbulho

Ademais, ressalte-se que os laudos antropológicos acima citados comprovam que a Comunidade Indígena Xokleng só não estava na área em 05 de outubro de 1988 em razão do contínuo processo de expropriação e expulsão sofrido ao longo do século passado. Primeiro, pela perseguição de bugreiros, que quase levaram o grupo ao extermínio. Depois, pela política de atração, com o intuito de liberar terras para a colonização, com a proibição, inicialmente pelos castigos, depois pelas invasões e cercamento de propriedades, de perambulação livre pela região em litígio.

Assim, ainda que se considere ser aplicável algum marco temporal à hipótese, é preciso apontar que a decisão prolatada na Pet nº 3.388 não se limitou a reconhecer a necessidade de presença física na data da promulgação da Constituição para a configuração da tutela constitucional à posse indígena, mas compreendeu que esse direito não se perderia quando configurado o renitente esbulho praticado contra a comunidade, que impedisse esse estar na terra tradicionalmente considerado:

> "11.2. **O marco da tradicionalidade da ocupação. É preciso que esse estar coletivamente situado em certo espaço fundiário também ostente o caráter da perdurabilidade, no sentido anímico e psíquico de continuidade etnográfica. A tradicionalidade da posse nativa, no entanto, não se perde onde, ao tempo da promulgação da Lei Maior de 1988, a reocupação apenas não ocorreu por efeito de renitente esbulho por parte de não-índios. Caso das "fazendas" situadas**

Cópia

> **na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, cuja ocupação não arrefeceu nos índios sua capacidade de resistência e de afirmação da sua peculiar presença em todo o complexo geográfico da "Raposa Serra do Sol**"."

Compreendo que referido acórdão não fixou critérios estanques para o reconhecimento do renitente esbulho, asseverando que a ocupação por não-índios das terras tradicionais "*não arrefeceu nos índios sua capacidade de resistência e de afirmação da sua peculiar presença em todo o completo geográfico da 'Raposa Serra do Sol'*".

Contudo, entendo insubsistente, com a devida vênia a entendimento diverso, a definição do conceito formulada no julgamento do ARE 803.462 AgR, pela Segunda Turma desta Corte:

> "Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TERRA INDÍGENA "LIMÃO VERDE". ÁREA TRADICIONALMENTE OCUPADA PELOS ÍNDIOS (ART. 231, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MARCO TEMPORAL. PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO. RENITENTE ESBULHO PERPETRADO POR NÃO ÍNDIOS: NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Pet 3.388, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 1º/7/2010, estabeleceu como marco temporal de ocupação da terra pelos índios, para efeito de reconhecimento como terra indígena, a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. 2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 650/STF, o conceito de "terras tradicionalmente ocupadas pelos índios" não abrange aquelas que eram possuídas pelos nativos no passado remoto. Precedente: RMS 29.087, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/10/2014. 3. **Renitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou com desocupação forçada, ocorrida no passado. Há de haver, para configuração de esbulho, situação de efetivo conflito possessório que, mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco demarcatório temporal atual (vale dizer, a data da**

Cópia

> **promulgação da Constituição de 1988), conflito que se materializa por circunstâncias de fato ou, pelo menos, por uma controvérsia possessória judicializada.** 4. Agravo regimental a que se dá provimento."
>
> (ARE 803462 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Duas foram as circunstâncias consideradas pelo referido julgado para caracterizar o renitente esbulho, a escusar a ausência da comunidade indígena no território pretendido, à data da promulgação da Constituição de 1988: controvérsia possessória judicializada ou um conflito deflagrado na área, ambas as hipóteses tendo perdurado até 05 de outubro de 1988.

Entretanto, é preciso problematizar esses requisitos, à luz do contido no artigo 231 da Carta Constitucional.

Em primeiro lugar, a exigência de "*controvérsia possessória judicializada*".

Referida exigência, com a devida vênia, não pode subsistir ao se levar em conta a realidade fática e jurídica da capacidade processual dos índios antes da Constituição de 1988.

De fato, desde o período colonial, estavam os indígenas brasileiros submetidos a regimes tutelares com a finalidade de aculturá-los e de promover sua assimilação progressiva ao novo território do colonizador branco e cristão.

No período republicano, em contraste com as previsões constitucionais que lhes garantiam a posse de suas terras, foram os indígenas qualificados como relativamente incapazes pela legislação civil, necessitando de tutela do órgão indigenista – à época da Codificação de 1916, o Serviço de Proteção ao Índio – SPI, e posteriormente a Fundação Nacional do Índio – FUNAI – para a prática de atos da vida civil, inclusive ingressar em juízo.

Eis a dicção do Código Civil de 1916:

> "Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147,

Cópia

> n. 1), ou à maneira de os exercer:
>
> I. Os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos (arts. 154 a 156).
>
> II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal.
>
> III. Os pródigos.
>
> **IV. Os silvícolas**.
>
> Parágrafo único. **Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiais, e que cessará à medida de sua adaptação**.

O intuito de assimilação do índio à sociedade nacional ficou explícito na legislação acima citada. E de forma ainda mais clara, a postura integracionista do Estado brasileiro restou ainda mais evidente no Estatuto do Índio, que estimulava o progressivo abandono da condição de indígena para a aquisição plena da capacidade de possuir direitos, como se depreende dos seguintes dispositivos:

> Art 4º Os índios são considerados:
>
> I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional;
>
> II - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento;
>
> III - Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura.
>
> Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.

Cópia

§ 1º Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber, os princípios e normas da tutela de direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória.

§ 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão federal de assistência aos silvícolas.

Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos.

Art. 9º Qualquer índio poderá requerer ao Juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto nesta Lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os requisitos seguintes:

I - idade mínima de 21 anos;

II - conhecimento da língua portuguesa;

III - habilitação para o exercício de atividade útil, na comunhão nacional;

IV - razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional.

Parágrafo único. O Juiz decidirá após instrução sumária, ouvidos o órgão de assistência ao índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no registro civil.

Art. 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a pedido escrito do interessado, o órgão de assistência poderá reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição de integrado, cessando toda restrição à capacidade, desde que, homologado judicialmente o ato, seja inscrito no registro civil.

Cópia

> Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser declarada a emancipação da comunidade indígena e de seus membros, quanto ao regime tutelar estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada, em inquérito realizado pelo órgão federal competente, a sua plena integração na comunhão nacional.

Especificamente em relação à capacidade processual, referida Lei assim dispõe:

> Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas.
>
> Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas para a defesa dos seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério Público Federal ou do órgão de proteção ao índio.

Cópia

Evidentemente, esses dispositivos não mais subsistem diante da ordem constitucional vigente, que atribui aos índios e comunidades, além do respeito ao seu modo de vida e suas tradições e costumes, capacidade plena para figurar em juízo na defesa de seus direitos, em seu artigo 232.

No que concerne, contudo, ao ajuizamento de demandas possessórias pelas comunidades, antes da Constituição de 1988, o cenário acima traçado permite inferir que os índios quase nunca se utilizariam desse recurso. A uma, porque se tratava de um modo de resistência obviamente integrante do modo de ser da sociedade envolvente, mas não dos indígenas, que possuem outras formas tradicionais de resolução de conflitos. A duas, porque dependiam sempre da intervenção do órgão indigenista e da União para tanto, e no contexto integracionista, muitas vezes os interesses eram bastante conflitantes.

Mesmo raciocínio pode-se aplicar ao segundo modo configurador do renitente esbulho, qual seja, a existência de um conflito materializado por

situações de fato, a perdurar até a data da Constituição de 88.

Em primeiro lugar, porque o ordenamento constitucional não poderia incentivar conflitos para legitimar e reconhecer direitos. De outra parte, os indígenas, tutelados pelo Estado, foram constantemente expulsos, assassinados e desintegrados de sua cultura, em nome de interesses privados e desenvolvimentistas. Nesse cenário, resistir aos conflitos de forma reiterada, a persistir até a data da promulgação da Carta Magna, seria enfrentar a morte quase certa, algo que também não parece ter sido a intenção do constituinte quando assegurou a posse das terras que ocupam de forma tradicional.

Esta Corte já decidiu que o abandono involuntário das terras tradicionais, perpetradas por meios violentos, não se presta a desconfigurar a tradicionalidade da ocupação:

> "Ementa: 1) AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEIS RURAIS SITUADOS NO SUL DA BAHIA EM RESERVA INDÍGENA. 2) CONFLITO GRAVE ENVOLVENDO COMUNIDADES SITUADAS NA RESERVA INDÍGENA DENOMINADA CARAMARUMU-CATARINA-PARAGUAÇU. AÇÃO JUDICIAL DISTRIBUÍDA EM 1982 IMPONDO A OBSERVÂNCIA DO REGIME JURÍDICO CONSTITUCIONAL DA CARTA DE 1967 PARA DISCIPLINAR A RELAÇÃO MATERIAL SUB JUDICE. 3) PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE REIVINDICADA. PRELIMINAR REJEITADA À LUZ DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE EM ÁREA INDÍGENA MERCÊ DA EXISTÊNCIA DE FARTA DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA FUNAI QUE VIABILIZOU A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS. 4) DEMARCAÇÃO DA ÁREA SUB JUDICE OCORRIDA EM 1938 DESACOMPANHADA DE HOMOLOGAÇÃO. INCERTEZA ORIUNDA DA AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA

Cópia

DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS RELEGANDO A COMUNIDADE A UMA SITUAÇÃO FRÁGIL E A UM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA E MEDO NA REGIÃO. 5) **A HOMOLOGAÇÃO AUSENTE, DA DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA EM 1938, NÃO INIBE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE RESERVA INDÍGENA NO LOCAL, ORIGINANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE TER POR VÁLIDOS ATOS JURÍDICOS FORMADOS POR PARTICULARES COM O ESTADO DA BAHIA. 6) AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRESENÇA DE ÍNDIOS NA ÁREA EM LITÍGIO DESDE O PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA CARTA DE 1967 EM FACE DOS REGISTROS HISTÓRICOS QUE REMONTAM A MEADOS DO SÉCULO XVII. 7) O RECONHECIMENTO DO DIREITO À POSSE PERMANENTE DOS SILVÍCOLAS INDEPENDE DA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO NA MEDIDA EM QUE A TUTELA DOS ÍNDIOS DECORRE, DESDE SEMPRE, DIRETAMENTE DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 8) A BAIXA DEMOGRAFIA INDÍGENA NA REGIÃO EM CONFLITO EM DETERMINADOS MOMENTOS HISTÓRICOS, PRINCIPALMENTE QUANDO DECORRENTE DE ESBULHOS PERPETRADOS POR FORASTEIROS, NÃO CONSUBSTANCIA ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO CARÁTER PERMANENTE DA POSSE DOS SILVÍCOLAS. A REMOÇÃO DOS ÍNDIOS DE SUAS TERRAS POR ATOS DE VIOLÊNCIA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR-LHES O RECONHECIMENTO DA TRADICIONALIDADE DE SUA POSSE. IN CASU, VISLUMBRA-SE A PERSISTÊNCIA NECESSÁRIA DA COMUNIDADE INDÍGENA PARA CONFIGURAR A CONTINUIDADE SUFICIENTE DA POSSE TIDA POR ESBULHADA. A POSSE OBTIDA POR MEIO VIOLENTO OU CLANDESTINO NÃO PODE OPOR-SE À POSSE JUSTA E CONSTITUICONALMENTE CONSAGRADA.** 9)

Cópia

NULIDADE DE TODOS OS TÍTULOS DE PROPRIEDADE CUJAS RESPECTIVAS GLEBAS ESTEJAM LOCALIZADAS DENTRO DA ÁREA DE RESERVA INDÍGENA DENOMINADA CARAMURU-CATARINA-PARAGUAÇU, CONFORME DEMARCAÇÃO DE 1938. AQUISIÇÃO A NON DOMINO QUE ACARRETA A NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE NA REFERIDA ÁREA INDÍGENA, PORQUANTO OS BENS TRANSFERIDOS SÃO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO (SÚMULA 480 DO STF: Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos artigos 4, IV, e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas). 10) A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO ERIGIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE QUE AS AÇÕES JUDICIAIS PENDENTES EM QUE SE DISCUTE O DOMÍNIO E/OU A POSSE DE IMÓVEIS SITUADOS NA ÁREA RECONHECIDA NESTE PROCESSO COMO RESERVA INDÍGENA SEJAM EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 11) O RESPEITO ÀS COMUNIDADES ÍNDIGENAS E À SUA CULTURA IMPLICA RESTE PRESERVADA A POSSIBILIDADE DE SUPERVENIENTE INCLUSÃO, PELA UNIÃO, ATRAVÉS DE DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA OU MESMO JUDICIAL, DE NOVAS ÁREAS NA RESERVA INDÍGENA CARAMURU-CATARINA-PARAGUAÇU ALÉM DA JÁ RECONHECIDA NESTES AUTOS. 12) DEVERAS, A EVENTUAL AMPLIAÇÃO DA ÁREA ANALISADA NESTES AUTOS EM RAZÃO DE DEMARCAÇÃO SUPERVENIENTE A ESTE JULGAMENTO DEMANDARÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O ESPAÇO GEOGRÁFICO OBJETO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO CONSTITUÍA TERRA TRADICIONALMENTE OCUPADA PELOS ÍNDIOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 13) AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE APENAS QUANTO AOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE E REGISTROS IMOBILIÁRIOS REFERENTES AOS IMÓVEIS ABRANGIDOS PELO ESPAÇO

Cópia

> GEOGRÁFICO DEMARCADO EM 1938 E COMPROVADO NESTES AUTOS, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 54 MIL HECTARES. SOB ESSE ÂNGULO, A AÇÃO FOI JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A CONDIÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE TERRA INDÍGENA SOBRE A TOTALIDADE DA ÁREA DEMARCADA EM 1938 E TOTALIZANDO CERCA DE 54 MIL HECTARES CORRESPONDENTES À RESERVA CARAMARU-CATARINA-PARAGUAÇU, E DECLARAR A NULIDADE DE TODOS OS TÍTULOS DE PROPRIEDADE CUJAS RESPECTIVAS GLEBAS ESTEJAM LOCALIZADAS NA ÁREA DA RESERVA. 14) AS RECONVENÇÕES RELATIVAS ÀS TERRAS SITUADAS NO INTERIOR DA ÁREA DEMARCADA EM 1938 IMPROCEDEM. CONDENAÇÃO DESSES RÉUS RECONVINTES, CUJOS TÍTULOS FORAM ANULADOS, A PAGAREM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E COMPENSADOS OS HONORÁRIOS DOS OUTROS RECONVINTES QUE DECAÍRAM DA RECONVENÇÃO.
>
> (ACO 312, Relator(a): EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2012, Dje-054 DIVULG 20-03-2013 PUBLIC 21-03-2013 EMENT VOL-02683-01 PP-00001)

Portanto, depreendo não incidir na hipótese o contido na Súmula 650 do STF ("*Os incisos I e XI do art. 20 da CF não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto*"), uma vez que a expulsão violenta da comunidade indígena não leva à configuração do abandono da terra para descaracterizá-la.

É preciso que esse abandono se revista de um caráter eminentemente voluntário por parte da comunidade, sem a configuração de qualquer forma de esbulho das terras por parte de terceiros, e sem a exigência de um conflito físico ou de uma demanda possessória ajuizada e em trâmite à data de 05 de outubro de 1988.

Compreendo, nesse ínterim, que o laudo pericial antropológico deixou muito esclarecida a questão acerca do esbulho sofrido pela

Comunidade Indígena Xokleng, a demonstrar tanto a violência sofrida pelos índios como as formas de resistência e de busca da recuperação de seu território, antes e depois da Constituição de 1988:

> "No entanto, o histórico e a motivação para exigirem seus direitos territoriais surgiram do seio da própria comunidade indígena Ibirama-LaKlãno. O que se verifica nos seus depoimentos (coerentes com registros de Santos, 1987:233), é que logo após 1952, quando se efetivou a colonização da Barra da Prata, que resultou na redução final do seu território, alguns indígenas se deslocaram até o Rio de Janeiro e Curitiba para apresentar queixas e buscar auxílio junto a instâncias governamentais. Posteriormente, após começarem a sofrer as primeiras consequências da construção da Barragem Norte (a saber, uma enchente em 1974 desabrigou a maioria da população indígena, tomada totalmente de surpresa), o movimento para reivindicar seus direitos de indenizações engendrou contatos com organizações da sociedade civil ligadas à causa indígena. Esta articulação política já estava configurada quando a Constituição de 1988 criou a possibilidade de processos de redelimitação de terras indígenas."

Logo, como já salientado acima, a saída temporária dos indígenas área não desfigura a ligação identitária da comunidade à terra. Eis o entendimento doutrinário:

> "Os povos e as comunidades tradicionais seguiram e seguem no limbo da invisibilidade jurídica por serem expoliados e expulsos de suas terras, seja por violência pública, seja por violência privada. Tais povos, resistindo À opressão sofrida, podem temporariamente se distanciar de suas terras originárias, mas não perdem sua identidade étnica, que está intrinsecamente ligada à terra, que originou a concepção de povo e que originou a própria comunidade.
>
> Em suma, é no reconhecimento do sentido de

Cópia

> pertencimento à terra que a comunidade se autorreconhece enquanto povo"
>
> (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés; SILVA, Liana Amin Lima. Marco temporal como retrocesso dos direitos territoriais originários indígenas e quilombolas. In: WOLKMER, Antonio Carlos; SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés; TARREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco. *Os direitos territoriais quilombolas: além do marco temporal*. Goiânia: Ed. Da PUC Goiás, 2016, p. 79)

Assim, demonstrado que a comunidade só não estava na posse de suas terras pelo processo oficial de esbulho e violência sofrido pelos índios, mas que nunca deixou de existir a "*capacidade de resistência e de afirmação da sua peculiar presença*" na área demarcada, rejeito o argumento de que não exercem posse tradicional nas terras.

Cópia

<u>Da possibilidade de redimensionamento das terras indígenas</u>

Os autores sustentam, ainda, que se trata de ampliação de terra indígena, uma vez que o Decreto Presidencial de 1996 homologou área de 14 mil hectares, aproximadamente, à Terra Indígena, consistindo o reconhecimento de que fazem os índios jus a 37 mil hectares, atingindo as propriedades dos autores, uma violação ao texto constitucional.

Efetivamente, no julgamento da Pet 3.388, a vedação à ampliação de terras indígenas foi incluída como uma das dezenove salvaguardas institucionais incluídas à parte dispositiva.

O i. Ministro Menezes Direito, que a propôs, assim justificou:

> "Além dos efeitos acima destacados, a homologação tem mais uma importante conseqüência pelo bem da segurança jurídica: a impossibilidade de revisão dos limites da terra indígena fixados na Portaria do Ministério da Justiça.
>
> Como já ressaltado, o procedimento de regularização da terra indígena é um procedimento destinado à apuração do fato

> indígena, isto é a presença indígena em 5/10/1988, com a sua respectiva extensão, esta determinada com base nas já suas referidas expressões.
>
> Ora, uma vez estabelecido e constatado esse fato, com base no qual terá sido homologada a área da terra indígena, não pode haver mais espaço ou ensejo para uma revisão dessa área.
>
> Cuida-se aqui de verdadeira preclusão administrativa, que impedirá qualquer discussão sobre a área e os limites homologados. Não se concebe que o poder-dever da administração de rever de ofício seus atos alcance a constatação de um fato cuja ocorrência e extensão decorreram de procedimento instaurado regularmente, com observância do contraditório. Desse procedimento resultou a consolidação de direitos individuais, como ocorre com propriedades imediatamente adjacentes à terra indígena, assim como outros interesses públicos ou particulares relacionados à área não abrangida pela terra indígena.
>
> A existência desses interesses, direitos de natureza individual consolidados com a não-abrangência na terra indígena, impede uma aplicação absoluta do poder-dever de revisão dos atos da administração, como bem reflete o disposto no art. 53 da Lei nº 9.784/99 e na Súmula nº 473 deste Supremo Tribunal Federal.
>
> No caso da identificação e da demarcação de terras indígenas, de todos os modos, estou convencido de que a definição da extensão da área, fruto da constatação do fato indígena, não abre espaço para nenhum tipo de revisão fundada na conveniência e oportunidade do administrador. A demarcação esgota a identificação, sendo vedada sua alteração."

Fundada na consideração de que a posse tradicional seria um fato, verificado na data de 05 de outubro de 1988, considerou-se ser vedada a ampliação de terras indígenas.

No entanto, como não compreendo ser o marco temporal um definidor da tutela constitucional à posse indígena, é preciso revisar a

questão sob outras luzes.

Evidentemente, não se trata, aqui, de considerar a hipótese de conveniência e oportunidade do Administrador ao revisar ato administrativo, pois em se tratando de terras indígenas, de direito fundamental dos povos indígenas, todos os estudos devem estar jungidos a demonstrar a efetiva ocorrência das características do §1º do artigo 231, inexistindo espaço para avaliação discricionária.

Entretanto, especialmente em se considerando a possibilidade de que muitas terras indígenas tenham sido demarcadas sem a estrita observância do artigo em comento (p. ex., sem a realização de laudo antropológico a afirmar a correta extensão das terras tradicionais), compreendo que a realização de re-estudos para o adequado dimensionamento da ocupação tradicional em tais áreas, desde que realizados em processo administrativo demarcatório nos termos da legislação de regência, não encontra vedação constitucional.

Esta Corte já admitiu que inconstitucionalidades flagrantes não se submetem a quaisquer prazos decadenciais ou prescricionais:

> "EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva

Cópia

> bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. **As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes**. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: "No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas."
>
> (RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020)

Portanto, se demonstrada flagrante inconstitucionalidade no que concerne ao cumprimento do artigo 231 da Constituição Federal, incorrendo em prejuízos às comunidades indígenas que se viram alijadas de parte de seu território tradicional, não compreendo existir vedação a eventual redimensionamento das terras já demarcadas.

No caso ora sob análise, compreendo que, como bem demonstrou o processo demarcatório, os estudos instaurados pela Portaria nº 418/PRES/95 foram os primeiros realizados na região, a fim de verificar a presença dos requisitos do artigo 231 do texto constitucional.

Com efeito, assim constou do laudo antropológico da FUNAI:

> "**Balizamento jurídico-administrativo que deve ser salientado é o fato de que a TI Ibirama foi homologada em 1996 sem nenhum trabalho de pesquisa cientifico a embasar tal ato. Assim, o presente Relatório é o primeiro estudo, pautado nos dispositivos constitucionais vigentes e suas bases normativas, i.é., o Art. 231 da Constituição Federal; o Decreto N.° 1775/96, que estabelece procedimentos administrativos de demarcação das terras indígenas no país; a Portaria 14, que estabelece as normas para a elaboração de Relatório Circunstanciado de Identificação das Terras Indígenas, que procede à uma identificação e definição de limites territoriais com finalidade precípua de caracterizar terras tradicionalmente ocupadas pelo povo Xokleng no Vale do Itajaí**."

Cópia

De fato, como se depreende do procedimento que iniciou o processo que homologou e promoveu o registro da TI Ibirama em 1996, não houve processo de identificação de terra indígena, nos termos seja do Decreto 1.775/96, seja do Decreto anteriormente vigente, de nº 22/1991. Como se verifica no apenso 26, tratou-se de mero avivamento de limites na área indígena Ibirama, iniciada em 1984 em razão das constantes reivindicações da Comunidade, que sofria as consequências da construção da Barragem Norte em suas terras.

Não houve processo administrativo demarcatório, com trabalho técnico a identificar corretamente a extensão da terra tradicionalmente indígena.

Assim, e em se considerando que o redimensionamento foi precedido do procedimento administrativo demarcatório contido no Decreto nº 1.775/1996, entendo hígida a demarcação realizada, que culminou na edição da Portaria nº 1.128/2003.

Compatibilidade da dupla afetação – ambiental e indígena – da área

A perícia cartográfica (Pet 75282/2010, volume 08/19 e ss.) demonstrou que a demarcação da Terra Indígena Ibirama sobrepõe-se à Área de Relevante Interesse Ecológico Serra da Abelha em 72% desta, bem como que representa 1,18% da área relativa à Reserva Biológica do Sassafrás.

Coloca-se, portanto, a questão referente à compatibilidade entre a ocupação tradicional indígena, segundo seus usos, costumes e tradições, e a proteção ao meio ambiente; esta já foi reconhecida no julgamento da Pet nº 3.388, nos seguintes termos:

> "15. A RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA ENTRE TERRAS INDÍGENAS E MEIO AMBIENTE. Há perfeita compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda que estas envolvam áreas de "conservação" e "preservação" ambiental. Essa compatibilidade é que autoriza a dupla afetação, sob a administração do competente órgão de defesa ambiental."

A regulamentação normativa da matéria foi realizada, no âmbito federal, pelo Decreto nº 7.477, de 5 de junho de 2012, que instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI.

O acórdão prolatado na Pet nº 3.388 compreendeu ser possível a dupla afetação da área ambientalmente protegida, mas colocando-a sob a administração do órgão de defesa ambiental, ouvidos os índios e a FUNAI a respeito das questões referentes à proteção ambiental.

Primeiramente, é necessário afirmar que a tutela constitucional dos direitos possessórios indígenas dá-se considerando o modo de vida típico de cada comunidade, em atenção a seus usos, costumes e tradições.

Conforme acima referido, a relação cosmológica dos índios com a Terra levam à proteção também das áreas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar. Portanto, a manutenção de um meio ambiente equilibrado é essencial para o desenvolvimento das atividades de caça, pesca, cultivo, além das espirituais e culturais das comunidades indígenas.

Cópia

Logo, não há incompatibilidade entre os artigos 231 e 225 do texto constitucional, pois os índios detém todo o interesse na proteção dessas áreas. A manutenção das florestas, da biodiversidade, de rios e lagos despoluídos, asseguram o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais, mantendo a qualidade de vida dessas comunidades. A dupla afetação entre terras indígenas e áreas de proteção ambiental não é inviável, ao revés, como demonstra o diploma normativo acima citado.

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, inclusive, informou na audiência de conciliação e diálogo, que já efetiva instrumentos para a gestão conjunta das áreas ambientais, com o que concordaram tanto a Comunidade Indígena como a FUNAI. É, de fato, o compromisso mais concreto saído da referida audiência, a demonstrar que a temática não enfrenta resistência, seja pelo órgão ambiental, seja pelos índios.

Nada obstante, em se considerando o direito originário das comunidades indígenas, as políticas de proteção ambiental não podem interferir no exercício das atividades tradicionais dos índios, a uma, porque não se configuram em ações predatórias ao meio ambiente, a duas, porque os usos, costumes e tradições indígenas consistem no núcleo do reconhecimento da tradicionalidade da ocupação tutelada pelo artigo 231 do texto constitucional.

Dessa feita, não compreendo existir incompatibilidade na chamada dupla afetação da área ambientalmente protegida, assegurado o direito das comunidades de participarem das decisões acerca da administração das unidades, nos termos do artigo 15 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, em consonância com o exercício da posse permanente e usufruto da terra indígena.

Nulidade dos títulos particulares e indenização

Formulam os Autores pedido sucessivo, nos seguintes termos:

> "e) **embora não se espere porque o pedido de anulação proferido pelos Autores se fundamenta em lídimo e escorreito**

> **direito, sucessivamente, requerem, ao menos, que esse R. Juízo declare o direito dos Autores ao recebimento de indenização tanto pela pelas benfeitorias erigidas de boa fé como pela terra nua, derivada de posse ou propriedade, na forma da fundamentação**, também condenando as Rés à custas do processo e honorários advocatícios;"

Por sua vez, a Comunidade Indígena Xokleng entende ser possível a indenização da terra nua aos agricultores, com lastro no artigo 37, §6º da Constituição, bem como do artigo 148-A da Constituição do Estado de Santa Catarina.

De fato, a previsão contida no §6º do artigo 231 da Constituição de 1988 possui conteúdo bastante semelhante àquele já contido na Carta derivada da Emenda nº 1/69, em seu artigo 198, §§ 1º e 2º:

> "Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos têrmos que a lei federal determinar, a êles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de tôdas as utilidades nelas existentes.
>
> § 1º Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas.
>
> § 2º A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do Índio."

Referida previsão foi reforçada pelo disposto no artigo 62 do Estatuto do Índio, *in verbis*:

> "Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas pelos índios ou comunidades indígenas.

Cópia

> § 1° Aplica-se o disposto deste artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular.
>
> § 2º Ninguém terá direito a ação ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao índio ou os silvícolas em virtude da nulidade e extinção de que trata este artigo, ou de suas conseqüências econômicas.
>
> § 3º Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao índio, será permitida a continuação, por prazo razoável dos efeitos dos contratos de arrendamento em vigor na data desta Lei, desde que a sua extinção acarrete graves conseqüências sociais."

Nada obstante, é possível afirmar que a nulidade dos títulos particulares em terras indígenas, considerada sua proteção constitucional desde a Constituição de 1934, operou-se a partir dessa Carta Constitucional, ainda que expedidos em período anterior, pois se as terras indígenas não eram terras devolutas, não poderia haver concessão a particulares, a menos que se tratasse de aldeamento extinto de forma voluntária.

Como afirma Deborah Duprat:

> "Veja-se que, não obstante a ausência de expressa previsão constitucional, a posse indígena e a localização permanente eram pressupostos, desde 1934, aptos a gerar a nulidade de qualquer título incidente sobre a respectiva área. Significa dizer que esse direito, com tais atributos, foi incorporado ao patrimônio indígena, e a inércia, desídia, ação ou omissão do Estado não têm potencialidade de neutralizá-lo."
>
> (DUPRAT, Deborah. O marco temporal de 5 de outubro de 1988: TI Limão Verde. In: CUNHA, Manuela Carneiro da; BARBOSA, Samuel (orgs). Direito dos povos indígenas em disputa. São Paulo: Editora Unesp, 2018, p. 49.)

A Constituição da República, portanto, repete o preceito que, em

Cópia

nome da posse tradicional indígena, compreende ser nulo e extinto título dominial ou possessório válido incidente nessas áreas afetadas à manutenção do modo de vida das comunidades indígenas, a consistir direito originário da etnia, ao dispor que "*São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé*".

Dessa forma, compreende-se que a cadeia dominial de determinada área, por si só considerada, não tem o condão de impedir procedimento demarcatório, diante da existência de direito originário à posse das terras tradicionalmente ocupadas, da proteção constitucional e normativa desse direito, desde antes do período republicano, bem como da consideração de que o texto constitucional reconhece a posse, mas não a constitui, donde não ser possível a existência de posse ou propriedade privada em terras indígenas.

Por essa razão, não se visualiza hipótese de conflito entre o direito de propriedade e a proteção à posse tradicional indígena, uma vez que o próprio texto constitucional já asseverou a consequência do reconhecimento da tradicionalidade de ocupação indígena em determinada área, a não mais subsistirem títulos privados nessas terras.

Outro aspecto referente ao dispositivo em comento, e que decorre da nulidade dos títulos dominiais, é a **impossibilidade de se pleitear indenização ou ação em face da União em razão da nulidade ou da extinção do título proprietário ou possessório, salvo quando às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé**.

A possibilidade de indenização por ato ilícito na venda de terras *a non domino*, em ação própria de natureza eminentemente reparatória, é questão a ser amadurecida pela doutrina e pela jurisprudência, mas **não aparenta colidir, em meu sentir, com a vedação da concessão de indenização pelo fato de encontrar-se a área inserida em terra indígena**.

No caso concreto, especialmente em virtude do disposto no artigo 148-A da Constituição do Estado de Santa Catarina, *in verbis:*

> "Art. 148-A. O Estado poderá promover, na forma da lei e por meio de convênios com outros entes federativos, o reassentamento ou a indenização dos pequenos agricultores que, de boa fé, estejam ocupando terras destinadas por meio de processo demarcatório, aos povos indígenas."

No caso concreto, contudo, por mais que a tese tenha a simpatia deste Relator, os Autores deduzem sua pretensão exclusivamente em relação à União e à FUNAI, figurando o Estado de Santa Catarina como litisconsorte ativo. Assim, resta de todo heterodoxo modificar a posição processual do ente estadual para abrir espaço à concretização desse meio de responsabilização civil.

Ainda, compreendo que referida possibilidade – indenização por venda a non domino, inseria no campo da responsabilidade civil – em hipótese alguma pode consistir em impedimento à finalização da demarcação administrativa, com a extrusão dos particulares da terra demarcada sem qualquer direito à retenção pela terra nua, ou prejudicar o exercício dos direitos possessórios das comunidades indígenas com fundamento no artigo 231 do texto constitucional.

Assim, por considerar que a Portaria nº 1.128/2003 não possui máculas, declarando de posse tradicional indígena a área da Terra Indígena Ibirama Laklaño, incide o disposto no artigo 231, § 6º da Constituição Federal, sendo nulos e extintos os títulos de ocupação, domínio e posse de terras que ali se localizam, não gerando, por esse fato, direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.

Aos proprietários que se enquadrem nos requisitos para participar dos programas de reforma agrária, aplica-se o disposto no artigo 4º do Decreto nº 1.776/95:

> "Art. 4° Verificada a presença de ocupantes não índios na

Cópia

> área sob demarcação, o órgão fundiário federal dará prioridade ao respectivo reassentamento, segundo o levantamento efetuado pelo grupo técnico, observada a legislação pertinente."

Da execução do acórdão

Creio, por fim, que a exemplo do que ocorreu no julgamento da Pet nº 3.388, não basta apenas finalizar o julgamento com a declaração de improcedência do pleito exordial.

Com efeito, a fim de garantir que conflitos não se instaurem na região, faz-se necessário que todas as fases em continuidade ao procedimento demarcatório ocorram de forma célere e escorreita.

A observância dos parâmetros do artigo 231 da Constituição da República fica reconhecida por este acórdão, e não pode mais ser debatida, administrativa ou judicialmente.

O processo administrativo foi paralisado na fase de demarcação física da área.

A FUNAI, em manifestação por ocasião da realização de audiência de conciliação e diálogo, compromete-se a promover a prosseguir nos trabalhos demarcatórios, nos seguintes prazos (Petição 34075/2019):

> "Inicialmente, **a FUNAI se compromete a realizar e concluir a demarcação física da Terra Indígena Ibirama Laklaño, em conformidade com o seguinte cronograma, o qual será cumprido mediante apoio policial a ser prestado pela União Federal (Força Nacional e/ou Polícia Federal) e pelo Estado de Santa Catarina (Polícia Civil e/ou Polícia Militar), garantindo-se, assim, a segurança dos profissionais *in loco***:
>
> a) **30 dias para readequação do projeto de demarcação física;**
>
> **b) 90 dias para o processo licitatório;**
>
> **c) 180 dias para a execução**.
>
> 1.2. Das indenizações.

Nos termos do art. 231, § 6º, da Constituição Federal, são nulos os atos que têm por objeto a posse, o domínio ou a ocupação de terras indígenas, não gerando nenhum direito à indenização, salvo no que tange às benfeitorias decorrentes de comprovada ocupação de boa-fé.

Assim, por expressa vedação constitucional, não há possibilidade de acordo para pagamento, pela FUNAI, de indenização relativa aos atos de ocupação, domínio ou posse de áreas inseridas nos limites da Terra Indígena Ibirama Laklãno. Cabe à Fundação, repita-se, apenas a indenização por benfeitorias de boa-fé.

(…)

Neste sentido – e tendo em vista a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina pela indevida emissão de títulos de propriedades incidentes sobre área terra indígena de ocupação tradicional, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal –, a FUNAI propõe efetuar o pagamento das indenizações por benfeitorias de boa-fé, restando ao Estado de Santa Catarina o pagamento de indenizações pelo valor da terra nua.

A Fundação se compromete a realizar, no prazo de 5 anos, o levantamento e o pagamento das benfeitorias de boa-fé, observando-se, para tanto, as diretrizes estabelecidas na Instrução Normativa SEI nº 2, de 3/2/2012, na Instrução Executiva nº 34/DPT/2000 (Manual de Levantamento Fundiário, Socioeconômico, Documental e Cartorial) e na Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Rurais nº 8799/85, da ABNT.

As etapas serão cumpridas de maneira gradual e concomitante, com estimativa de levantamento fundiário de 120 ocupantes por ano, sempre com apoio da União Federal (Força Nacional e/ou Polícia Federal) e do Estado de Santa Catarina (Polícia Civil e/ou Militar), a fim de garantir a segurança dos profissionais *in loco*.

Os prazos acima indicados foram estabelecidos a partir de estimativa elaborada com base: a) nos procedimentos burocráticos envolvidos; b) na complexidade técnica do

Cópia

> **trabalho a ser desenvolvido; c) no quadro técnico – deficitário – da Fundação; d) na necessidade de qualificação das informações a serem colhidas em campo; e) no número de ocupantes não-índios**.
>
> **A ordem dos trabalhos será elaborada a partir da indicação, pela própria comunidade indígena, das áreas/regiões prioritárias**."

Os prazos acima parecem razoáveis, especialmente em se considerando que a própria comunidade indicará áreas prioritárias para desintrusão mais imediata, garantindo o progressivo suprimento de suas necessidades, com o correspondente pagamento de indenização pelas benfeitorias aos proprietários de boa-fé.

Tomo, portanto, os prazos acima como passíveis de cumprimento pelo órgão indigenista, e indicativos para o cumprimento do presente acórdão, a se processar perante este Tribunal, com eventual auxílio do Juízo Federal da Subseção de Blumenau/SC.

Declaro, portanto, constitucional a Portaria nº 1128, de 14/08/2003, exarada pelo Ministro da Justiça.

Cópia

Conclusão

Voto pela improcedência da Ação Cível Originária, declarando a higidez constitucional da Portaria nº 1.128, de 14/08/2003, exarada pelo Ministro da Justiça, que declarou de posse permanente dos grupos Xokleng, Kaingang e Guarani a Terra Indígena Ibirama-Laklaño, com superfície aproximada de 37.108 (trinta e sete mil cento e oito) hectares.

Condeno a parte autora ao pagamento definitivo das despesas processuais, bem como dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios da parte ré em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o contido no artigo 98, §3º do CPC, quanto aos requerentes beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Julgo, ainda, prejudicado o agravo regimental interposto pela União, em face da decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória incidental.

É como voto.

Cópia